

HANS KEISEN

TEORÍA GENERAL DEL DERECHO Y DEL ESTADO

Traducción: Eduardo García Máynez



FACULTAD DE DERECHO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
MÉXICO 1988

NOMOESTATICA

I. EL CONCEPTO DEL DERECHO

A) DERECHO Y JUSTICIA

2) *La conducta humana como objeto de regulación normativa*

El derecho es un orden de la conducta humana. Un "orden" es un conjunto de normas. El derecho no es, como a veces se dice, una norma. Es un conjunto de normas que tienen el tipo de unidad a que nos referimos cuando hablamos de un sistema. Es imposible captar la naturaleza del derecho si limitamos nuestra atención a una sola norma aislada. Las relaciones entre las normas de un orden jurídico son también esenciales a la naturaleza del derecho. Únicamente sobre la base de una clara comprensión de las relaciones que constituyen un ordenamiento jurídico, puede entenderse plenamente la naturaleza del derecho.

El aserto de que éste es un orden de la conducta humana no significa que se refiera exclusivamente a la conducta de los individuos, o que sólo la conducta humana constituya el contenido de las normas jurídicas. Una norma que da al homicidio el carácter de hecho punible se refiere a la conducta que tiene como consecuencia la muerte de un hombre. La muerte misma, sin embargo, no es conducta humana, sino un proceso fisiológico. Cada norma jurídica obliga a determinados seres humanos a observar, en ciertas circunstancias, una conducta determinada. Tales circunstancias no se refieren necesariamente a la conducta humana, sino que pueden consistir, por ejemplo, en lo que llamamos acontecimientos naturales. Una norma de derecho puede obligar a los vecinos a prestar ayuda a las víctimas de una inundación. La inundación no es conducta humana, sino condición de un proceder prescrito por el orden jurídico. En este sentido, hechos que no

representan un comportamiento humano pueden entrar en el contenido de una norma de derecho. Pero sólo pertenecen a tal contenido en cuanto se refieren a la conducta humana, ya como condición, ya como efecto de la misma.

Podría parecer que lo anterior sólo es aplicable al derecho de los pueblos civilizados. En el derecho primitivo, animales e incluso plantas y otros objetos inanimados son a menudo considerados en la misma forma que los seres humanos, y a veces se les impone un castigo.¹ Sin embargo, este hecho debe ser estudiado en su conexión con el animismo del hombre primitivo. Considera éste a los animales, las plantas y los objetos inanimados, como dotados de un "alma", en cuanto les atribuye facultades mentales humanas e incluso, algunas veces, sobrehumanas. La diferencia fundamental entre los seres humanos y los demás seres, que constituye una parte de la actitud del hombre civilizado, no existe para el primitivo. Y el segundo aplica su derecho a seres no humanos porque para él son humanos o, al menos, semejantes al hombre. En este sentido, el derecho primitivo es, igualmente, un orden de la conducta humana.

Pero al lado del derecho hay otros órdenes de la conducta del hombre, como la moral y la religión. Una definición del derecho debe especificar en qué respectos difiere el derecho de esos otros ordenamientos de la conducta humana.

b) *Definición científica y definición política del derecho*

Cualquier intento de definición de un concepto debe tomar como punto de partida el uso común de la palabra que designa el concepto en cuestión. Al definir la noción del derecho, debemos empezar por examinar los

¹ En la antigüedad había en Atenas un tribunal especial cuya función consistía en condenar a objetos inanimados, por ejemplo, una lanza con la cual un hombre había sido muerto. En su *Oración contra Aristócrates*, 76 (Trad. inglesa por J. H. Vince, 1935, págs. 267), dice Demóstenes: "Hay también un cuarto tribunal, el del Prítaneo. Su función consiste en que si un hombre es herido por una piedra, o por una pieza de madera o de hierro o por cualquier otro objeto de la misma especie que cae sobre él, y alguien, sin saber quién lo arrojó, conoce y posee el instrumento homicida, el tribunal debe proceder contra dicho instrumento". (Cf. también Platon, *Las leyes*, 873, y Aristóteles, *Althemestium Res Publica*, cap. 57. En la Edad Media era todavía posible seguir un proceso contra un animal, por ejemplo, un toro o un toro que había matado a un hombre, o langostas que causaban un daño al destruir la cosecha, y el tribunal condenaba a muerte al animal acusado, después de lo cual era ejecutado, exactamente en la misma forma que un ser humano. Cf. Karl Von Amira, *Thierstrafen und Thierprocesse* (1892).

siguientes problemas: ¿presentan los fenómenos sociales generalmente denominados "derecho" una característica común que los distinga de otros fenómenos sociales de naturaleza semejante? ¿Tiene esa característica tal importancia en la vida social del hombre que podamos hacer de ella la base de un concepto capaz de servir para el conocimiento de esa misma vida? Por razones de economía de pensamiento, cabe partir del uso más amplio de la palabra "derecho". Tal vez no sea posible encontrar una característica del tipo de la que estamos buscando. Acaso el uso actual es tan vago que el fenómeno llamado "derecho" no presenta ninguna característica común verdaderamente importante. Pero si tal característica puede ser descubierta, la inclusión de la misma en la definición se justificará plenamente.

Ello no significa que sea ilegítimo acuñar un concepto más estricto del derecho, que no abarque todos los fenómenos usualmente designados por la misma palabra. Podemos definir a nuestro arbitrio aquellos términos que deseamos emplear como instrumentos de nuestro trabajo intelectual. El único problema es saber si podrán servir para el fin técnico que les hemos asignado. Un concepto del derecho cuya extensión coincide de manera aproximada con el uso común, es obviamente —en circunstancias iguales— preferible a otro sólo aplicable a una clase de fenómenos mucho más pequeña. Pongamos un ejemplo: desde el advenimiento del bolchevismo, del nacional-socialismo y del fascismo, se habla de "derecho" ruso, alemán e italiano. Sin embargo, nada podría impedirnos incluir en nuestra definición del orden jurídico cierto minimum de libertad personal, así como la posibilidad de la propiedad privada. La consecuencia de adoptar semejante definición sería que los ordenamientos sociales que existen en Rusia, Italia y Alemania no podrían ser ya considerados como jurídicos, a pesar de tener en común con el orden social de los Estados democrático-capitalistas, elementos muy importantes.

El concepto mencionado anteriormente —defendido en obras recientes de filosofía del derecho— revela también hasta qué punto una tendencia política puede influir sobre la definición del derecho. El concepto del derecho se hace entonces coincidir con un ideal específico de justicia, a saber, el de la democracia y el liberalismo. Desde el punto de vista de la ciencia, libre de toda clase de juicios de valor morales o políticos, la democracia y el liberalismo son únicamente dos principios posibles de organización social, lo mismo que la autocracia y el socialismo. No hay ninguna razón científica por la que el concepto del derecho tuviera que definirse de tal modo que excluyese las dos últimas clases de organización de la sociedad. Tal como

lo empleamos en estas investigaciones, no tiene connotación moral ninguna. Designa una técnica específica de organización social. En cuanto problema científico, el del derecho es un problema de técnica social, no un problema ético. El aserto "un cierto orden social tiene el carácter de derecho o es un orden jurídico", no implica ningún juicio moral, en el sentido de que tal orden sea bueno o justo. Hay ordenamientos jurídicos que, desde cierto punto de vista, son injustos. Derecho y justicia son conceptos diferentes. En cuanto lo distinguimos de la justicia, el orden jurídico aparece como derecho positivo. Este libro se limita a estudiar el concepto del derecho positivo y, por tanto, debe distinguir claramente la ciencia del derecho positivo y la filosofía de la justicia.

c) *El concepto del derecho y la idea de la justicia*

Libertar el concepto del derecho de la idea de la justicia es difícil, porque ambos se confunden constantemente en el pensamiento político no científico, así como en el lenguaje cotidiano, y porque esta confusión corresponde a la tendencia ideológica que trata de hacer aparecer el derecho positivo como justo. Si el derecho y la justicia son identificados y sólo un orden justo es llamado derecho, un orden social presentado como jurídico aparece —al mismo tiempo— como justo, esto es, como moralmente justificado. La tendencia a identificar derecho y justicia es la tendencia a justificar un orden social dado. No se trata de una tendencia científica, sino política. De acuerdo con ella, el esfuerzo de tratar el derecho y la justicia como problemas diferentes despierta la sospecha de que se trata de repudiar, al mismo tiempo, la exigencia de que el derecho positivo sea justo. Tal exigencia es evidente por sí misma; pero lo que en realidad significa es una cuestión diversa. Una teoría pura del derecho de ningún modo se opone a la exigencia de un derecho justo cuando se declara a sí misma incompetente para resolver la cuestión de si un determinado derecho es justo o no, o el problema acerca de cuál sea el elemento esencial a la justicia. Una teoría pura del derecho —en cuanto ciencia— no puede contestar esa pregunta, en virtud de que es imposible en absoluto responder a ella científicamente.

¿Qué es lo que realmente significa la afirmación de que un orden social es justo? Significa que ese orden regula la conducta de los hombres en una forma satisfactoria para todos, es decir, de tal modo que todos en-

cuentren en él su felicidad. La aspiración a la justicia es el eterno anhelo humano de felicidad. El individuo aislado no puede, en cuanto tal, encontrar la felicidad, y por ello la busca en la sociedad. Justicia es felicidad social.

1. La justicia como juicio subjetivo de valor.

Es obvio que no puede existir un orden justo, esto es, capaz de procurar la felicidad de cada uno, si el concepto de felicidad se define en su sentido originario y estricto de felicidad individual, y se entiende por felicidad de un hombre lo que éste considera como tal. Porque entonces resulta inevitable que en cierto momento la felicidad de una voluntad individual entre directamente en conflicto con la de otra voluntad. Tampoco es posible un orden justo en el supuesto de que lo que se trate de realizar no sea la felicidad de cada uno, sino la mayor felicidad del mayor número posible de individuos. La felicidad que un orden social es capaz de asegurar puede ser únicamente felicidad en sentido colectivo, esto es, la satisfacción de ciertas necesidades, reconocidas por la autoridad social, el legislador, como dignas de ser satisfechas, tales como la necesidad de alimentos, vestidos y habitación. Pero ¿qué necesidades humanas son dignas de ser satisfechas y, sobre todo, cuál es el orden jerárquico que les corresponde? Estos problemas no pueden ser resueltos por medio de un conocimiento racional. La solución de los mismos implica un juicio de valor determinado por factores emocionales y tiene, por ende, carácter subjetivo, válido únicamente para el sujeto que juzga y, por tanto, relativo sólo a él. La respuesta sería diferente según que proviniese de un creyente cristiano que considera el bien de su alma en el otro mundo más importante que los bienes terrenos, o de un materialista que no cree en otra vida; y sería también diferente si proviniese de quien considera la libertad personal como el bien más alto, en el caso del liberalismo, por ejemplo, o de quien piensa que la seguridad social y la igualdad de todos los hombres es superior a la libertad, como ocurre en el socialismo.

La cuestión que consiste en saber si los bienes espirituales o materiales, si la libertad o la igualdad representan el valor supremo, no puede ser resuelta racionalmente. Sin embargo, el juicio de valor subjetivo y, por tanto, relativo, mediante el cual la cuestión es decidida, suele ser presentado como un aserto que tiene valor objetivo y absoluto, es decir, como norma dotada de validez general. Constituye una peculiaridad del ser humano la de tener una profunda necesidad de justificar su conducta, la expresión

de sus emociones, sus anhelos y deseos, a través de la función de su intelecto, su pensamiento y su facultad cognoscitiva. Esto es posible, al menos en principio, en la medida en que los anhelos y deseos se refieren a medios por los cuales alguna finalidad puede alcanzarse; pues la relación entre medios y fines es una relación de causa a efecto, y puede determinarse sobre la base de la experiencia, esto es, racionalmente. De acuerdo con el estado actual de la ciencia social muchas veces ello no es posible, ya que en gran número de casos no tenemos una experiencia adecuada que nos capacite para determinar en qué forma ciertas finalidades sociales puedan ser realizadas con mayor eficacia. En consecuencia, este problema de los medios adecuados es a menudo resuelto de acuerdo con juicios subjetivos de valor, más bien que por un conocimiento objetivo de la conexión entre medios y fines, esto es, entre causas y efectos; de aquí que, al menos por el momento, el problema de la justicia, incluso como determinación de los medios adecuados para alcanzar un fin generalmente reconocido, no siempre pueda ser resuelto en una forma racional. La pugna entre liberalismo y socialismo, por ejemplo, en gran parte versa no sobre el objeto de la sociedad, sino más bien sobre el procedimiento correcto para conseguir una meta en la cual los hombres se hallan en gran medida de acuerdo; y, al menos por ahora, esta pugna no puede ser científicamente liquidada.

El juicio por el cual se declara que algo es un medio eficaz para un fin postulado de antemano, no es un verdadero juicio de valor; es —según se ha dicho— relativo a la conexión entre causa y efecto y, como tal, un juicio sobre la realidad. Juicio de valor es un aserto por el cual se declara que algo es un fin, un último fin que no puede servir como medio para el logro de otro fin ulterior. Semejante juicio se halla siempre determinado por factores emocionales.

La justificación de la función emocional por otra racional se halla, sin embargo, excluida en principio cuando se trata de últimos fines que ya no pueden ser medios para finalidades más elevadas.

Si la afirmación de los últimos fines aparece en la forma de postulados o normas de justicia, éstos descansan siempre en juicios de valor puramente subjetivos y, por ende, relativos. Por sabido se calla que gran número de esos juicios subjetivos son muy diferentes y, a veces, irreconciliables entre sí. Lo anterior no significa, por supuesto, que cada individuo tenga un sistema propio de valores. De hecho, gran número de individuos coincide en sus juicios de valor. Un sistema positivo de valores no es creación arbitraria del individuo aislado, sino siempre resultado de la influencia reci-

proca que los individuos ejercen unos sobre otros, dentro de un determinado grupo, familia, tribu, clase, casta o profesión. Los sistemas de valores, especialmente el moral y su idea central de la justicia, son fenómenos colectivos, productos sociales y, por consiguiente, difieren en cada caso de acuerdo con la naturaleza de la sociedad en cuyo seno surgen. El hecho de que en una determinada sociedad haya ciertos valores generalmente aceptados, en modo alguno contradice el carácter subjetivo y relativo de esos juicios de valor. La circunstancia de que muchos individuos coincidan en sus juicios estimativos no prueba que tales juicios sean correctos. Del mismo modo, la circunstancia de que un gran número de gente crea o haya creído que el sol gira alrededor de la tierra, no es ni era prueba de la verdad de dicha idea. El criterio de la justicia, como el de la verdad, no depende de la frecuencia con la cual se hagan determinados juicios sobre la realidad o determinados juicios valorativos.

Como la humanidad está dividida en muchas naciones, clases, religiones, profesiones, etc., a menudo en desacuerdo recíproco, hay una gran multiplicidad de ideas sobre lo justo; tantas, que resulta imposible hablar simplemente de "justicia".

2. Derecho natural.

Todo individuo se siente inclinado a postular su propia idea de la justicia como la única correcta o absolutamente válida. La necesidad de una justificación racional de nuestros actos emocionales es tan grande, que tratamos de satisfacerla aun a riesgo de engañarnos a nosotros mismos. Y la justificación racional de un postulado que se basa en un juicio subjetivo de valor, esto es, en un deseo, en el que todos los hombres sean libres, por ejemplo, o en el de que sean tratados igualmente, es un autoengaño o —lo que equivale a lo mismo— una ideología. Ideologías típicas de esta clase son las afirmaciones de que determinada especie de último fin y, por tanto, determinada regulación de la conducta humana, derivan de la "naturaleza", esto es, de la de las cosas o de la del hombre, de la razón humana o de la voluntad divina. En este punto radica la esencia de la doctrina del llamado derecho natural. Sostiene esta doctrina que hay una ordenación de las relaciones humanas diferente del derecho positivo, superior a éste y absolutamente válida y justa, en cuanto oriunda de la naturaleza, de la razón humana o de la voluntad de Dios.

La voluntad divina —en la doctrina del derecho natural— es idéntica a la naturaleza, en la medida en que la segunda es concebida como creada por Dios, y las leyes de la misma como expresión de su voluntad. Consecuentemente, las leyes de la naturaleza poseen, de acuerdo con tal teoría, el mismo carácter que se atribuye a las normas jurídicas promulgadas por un legislador: son mandatos dirigidos a la naturaleza, que obedece esos mandatos o leyes en la misma forma en que el individuo acata las dictadas por un legislador.² El derecho creado por un legislador, es decir, por un acto de voluntad de autoridad humana, es derecho positivo. El natural, de acuerdo con su doctrina específica, no es creado por el acto de la voluntad humana; no es producto artificial o arbitrario del hombre. Puede ser y ha sido deducido de la naturaleza por una operación mental. Examinando cuidadosamente a ésta, especialmente la del hombre en sus relaciones con

² Blackstone, *Commentaries on the laws of England*, párrafos 36 y 39: "Ley en su sentido más general y comprensivo, significa una regla de acción; y se aplica indistintamente a todas las clases de acción, animadas e inanimadas, racionales e irracionales. Por ello hablamos de las leyes del movimiento, de la gravitación, de la óptica o de la mecánica, lo mismo que de leyes de la naturaleza y de las naciones. Se trata de esa regla de acción prescrita por un superior y que el inferior está obligado a obedecer. Así, cuando el Ser Supremo formó el universo y creó la materia de la nada, dejó impresos en esa materia ciertos principios, de los que nunca puede apartarse, y en ausencia de los cuales dejaría de ser. Cuando puso la materia en movimiento, estableció ciertas leyes de tal movimiento a las que todos los cuerpos que se mueven tienen que conformarse... Esta, en consecuencia, es la significación general de la ley: una regla de acción dictada por un ser superior; y, en aquellas criaturas que no tienen el poder de pensar ni el de querer, las leyes que las rigen tienen que ser invariablemente obedecidas, en tanto la criatura subsiste, puesto que su existencia depende de tal sometimiento. Pero las leyes, en su sentido más estricto, en el cual se trata ahora de considerarla, no son reglas de acción en general, sino de la *humana* o conducta: esto es, los preceptos por los cuales el hombre, el más noble de todos los seres sublimares, criatura dotada a la vez de razón y libre arbitrio, recibe la orden de hacer uso de tales facultades en la regulación general de su comportamiento." — "Como el hombre depende absolutamente de su Creador en todas las cosas, es necesario que en todas ellas se sujete a la voluntad de éste. Tal voluntad de su Creador es llamada ley de la naturaleza, pues así como Dios, cuando creó la materia, sometióla al principio de la movilidad, estableció ciertas reglas para la dirección perpetua del movimiento, del mismo modo, al crear al hombre y dotarlo de una voluntad libre para conducirse a sí mismo en todos los momentos de su vida, estableció ciertas leyes inmutables de la humana naturaleza, por las cuales esa libre voluntad se encuentra en cierto grado regida y limitada, y le dio también la facultad de razonar para descubrir el significado de tales leyes... El ha establecido únicamente aquellas leyes fundadas en las relaciones de justicia que existían en la naturaleza de las cosas antes del establecimiento de cualquier precepto positivo. Son éstas las eternas e inmutables leyes del bien y del mal, a las cuales el mismo Creador se conforma en todas sus dispensaciones; leyes que de acuerdo con la voluntad de éste la razón humana es capaz de descubrir, hasta donde son necesarias para la dirección de las acciones del hombre."

otros hombres, podemos encontrar las reglas que norman la conducta humana en una forma correspondiente a la naturaleza y, por tanto, perfectamente justa. Los derechos y deberes del hombre, establecidos por esta ley natural, son considerados como innatos en el individuo, en cuanto o implantados en él por la naturaleza y no impuestos o concedidos a éste por un legislador humano; y en cuanto la naturaleza manifiesta la voluntad de Dios, tales derechos y deberes son sagrados.

Sin embargo, ninguna de las numerosas teorías sobre el derecho natural ha logrado definir con éxito el contenido de ese orden justo en una forma que siquiera se aproxime a la exactitud y objetividad con la cual la ciencia natural puede determinar el contenido de sus leyes, o la jurídica el contenido de un ordenamiento positivo. Lo que ha sido presentado como derecho natural o, lo que equivale a lo mismo, como justicia, consiste en su mayor parte en fórmulas vacías, como *summum cuique*, "a cada quien lo suyo", o tautologías desprovistas de significado, como el imperativo categórico, esto es, la doctrina kantiana de que uno debe hallarse determinado solamente por principios que pueda querer que sean obligatorios para todos los hombres. Pero la fórmula "a cada quien lo suyo", no contesta la pregunta sobre qué es lo suyo de cada quien, y el imperativo categórico no dice cuáles son los principios que uno debiera querer se transformasen en obligatorios para todos. Algunos escritores definen la justicia por medio de la fórmula "debes hacer el bien y evitar el mal". Pero ¿qué es el bien y qué el mal? Esta es la cuestión decisiva, y tal cuestión permanece sin respuesta. Casi todas las famosas definiciones de la justicia suponen de antemano que la respuesta esperada es evidente por sí misma. Pero tal respuesta en modo alguno tiene ese carácter. De hecho, la respuesta a la pregunta sobre qué es lo suyo de cada quien, o cuál debe ser el contenido de los principios generales obligatorios para todos los hombres, o qué es lo bueno y qué lo malo, se supone debe ser dada por el derecho positivo. Consecuentemente, todas esas fórmulas de justicia tienen como resultado justificar cualquier orden jurídico positivo. Permiten que cualquier orden positivo deseado por nosotros aparezca como justo.

Cuando las normas que se pretende son "la ley de la naturaleza" o la expresión de la justicia tienen un contenido definido, aparecen como principios más o menos generalizados de un determinado derecho positivo y, sin razón suficiente para ello, son postuladas como absolutamente válidas, o de derecho justo o natural.

Entre los llamados derechos naturales, innatos y sagrados del hombre, la propiedad privada desempeña un papel importante, si no el de mayor importancia. Casi todos los escritores que encabezan el movimiento afirmador del derecho natural sostienen que la institución de la propiedad privada corresponde a la naturaleza intrínseca del hombre. Consecuentemente, un orden jurídico que no la garantiza y protege es declarado contrario a la naturaleza y, por tanto, no se le concede larga duración. "Desde el momento en que en la sociedad se admite la idea de que la propiedad no es tan sagrada como las leyes de Dios y de que no hay un poder legal y una justicia pública para protegerla, comienzan la anarquía y la tiranía. Si las normas 'no debes codiciar' y 'no debes robar' (que presuponen la institución de la propiedad privada), no fuesen mandamientos del cielo, tendrían que ser convertidas en preceptos inviolables en cada sociedad, antes de que ésta pudiera ser civilizada o hecha libre."³ John Adams fue quien escribió estas frases, expresando con ellas una convicción generalmente admitida en su época. De acuerdo con tal teoría, una organización comunista que suprime la propiedad privada y reconoce únicamente la pública, un orden que reserva la propiedad de la tierra y de otros medios de producción a la comunidad, especialmente al Estado, no sólo es contrario a la naturaleza y, por tanto, injusto, sino también prácticamente insostenible.

Resulta, sin embargo, casi imposible probar esta doctrina; al lado de ordenamientos jurídicos que instituyen la propiedad privada, la historia revela otros que sólo la reconocen en forma muy restringida. Sabemos de sociedades agrícolas relativamente primitivas en donde el bien más importante, la tierra, no es propiedad de los particulares, sino de la comunidad; y las experiencias de los últimos 25 años demuestran que incluso dentro de un Estado poderoso y fuertemente industrializado, una organización comunista es perfectamente posible. Otra cuestión es la de decidir cuál sistema es mejor, el capitalista basado en el principio de la propiedad privada, o el comunista, que se basa en el de la propiedad pública. En cualquier caso, la propiedad privada no es históricamente el único principio en que pueda basarse un orden jurídico. Declarar que aquélla es un derecho natural por ser la única que corresponde a la naturaleza, es un ensayo que tiende a dar carácter absoluto a un principio especial que históricamente sólo se ha convertido en derecho positivo en una cierta época y en determinadas condiciones políticas y económicas.

³ *Works of John Adams* (1851), 9.

Igualmente sucede, aun cuando con menos frecuencia, que los principios postulados como "naturales" o "justos" se oponen a un determinado derecho positivo. También el socialismo ha sido defendido por el método específico de la doctrina del derecho natural, y algunos han declarado que la propiedad privada es contraria a la naturaleza. Con semejante método siempre es posible sostener y en apariencia probar postulados contradictorios. Si los principios del derecho natural son presentados para aprobar o desaprobar un orden jurídico positivo, su validez descansa en cualquiera de los dos casos en juicios de valor, desprovistos de objetividad. Un análisis crítico revela siempre que éstos no son otra cosa que la expresión de ciertos intereses de grupo o de clase. De acuerdo con ello, la doctrina del derecho natural es a veces conservadora, a veces reformadora o revolucionaria. Ya justifica al derecho positivo al proclamar su conformidad —afirmada pero no probada— con el orden natural, razonable o divino, ya pone en tela de juicio la validez del derecho positivo, al sostener que se halla en contradicción con alguno de los principios postulados de antemano como absolutos. La doctrina revolucionaria del derecho natural, lo mismo que la conservadora, no se refiere al conocimiento del derecho positivo, de la realidad jurídica, sino a su defensa o ataque, y, por ende, su tarea no es científica, sino política.⁴

3. El dualismo de derecho positivo y derecho natural.⁵

La doctrina del derecho natural se caracteriza por el establecimiento de un dualismo fundamental entre derecho positivo y derecho natural. Por encima del imperfecto derecho positivo existe un derecho natural perfecto, absolutamente justo; y aquél se justifica únicamente en la medida en que corresponde al natural. El dualismo de los derechos positivo y natural, característico de la doctrina, se asemeja en tal respecto al dualismo meta-

⁴ Roscoe Pound, en su obra titulada *An Introduction to the Philosophy of Law*, dice: "La concepción del derecho natural como algo de lo cual el derecho positivo es meramente declaratorio, y por lo cual las normas vigentes tienen que ser juzgadas y con lo cual tienen que coincidir en la mayor medida posible; por lo cual nuevas normas tienen que ser creadas y las antiguas aplicadas o restringidas en su aplicación, era un poderoso instrumento en las manos de los juristas y los ponía en condiciones de proceder en su tarea de construcción jurídica con una segura confianza." ¡Un "poderoso instrumento" en verdad! Pero este instrumento es una mera ideología, o, para usar un término más familiar a los juristas, una ficción.

⁵ Cf. el apéndice de la edición inglesa.

físico de la realidad y la idea platónica. El centro de la filosofía de Platón es la doctrina de las ideas. De acuerdo con dicha doctrina —que tiene un carácter totalmente dualista— hallase el mundo dividido en dos esferas diferentes: una es el mundo visible que sólo podemos percibir a través de nuestros sentidos y al cual damos el nombre de realidad; la otra está constituida por el mundo invisible de las ideas. Cada objeto del mundo visible tiene su patrón ideal o arquetipo en el invisible. Las cosas en el orden de la sensibilidad son sólo copias imperfectas, sombras, por decirlo así, de las ideas que existen en el mundo invisible. El dualismo entre realidad e idea, entre el mundo imperfecto de nuestros sentidos y otro mundo perfecto, inaccesible a la experiencia de los mismos sentidos, es decir, el dualismo entre naturaleza y supernaturaleza, entre lo natural y lo sobrenatural, lo empírico y lo trascendente, el más acá y el más allá, esta reduplicación del universo,⁶ no es sólo un elemento de la filosofía platónica, sino ingrediente típico de toda interpretación metafísica o, lo que es lo mismo, religiosa, de lo existente. Tal dualismo tiene a veces un carácter optimista y conservador, a veces pesimista y revolucionario, según que se pretenda que hay conformidad o contradicción entre la realidad empírica y las ideas trascendentes. El propósito de semejar metafísica no es, como el de la ciencia, explicar racionalmente la realidad, sino más bien aceptarla o rechazarla en actitud emocional. Y el sujeto es libre para elegir la primera o la segunda de esas interpretaciones de la relación entre la realidad y las ideas, porque el conocimiento objetivo de estas últimas no es posible, a causa del carácter trascendente implicado en su misma definición. Si el hombre tuviese un conocimiento cabal del reino de las ideas, estaría en condiciones de adaptar su mundo, especialmente su mundo social, su conducta, a ese arquetipo; y como se convertiría en un ser perfectamente feliz si su conducta correspondiese a dicho ideal, seguro es que se conduciría de tal manera. Tanto él como su mundo empírico devendrían enteramente buenos. No habría ya, en consecuencia, un mundo real empírico diferente del mundo ideal trascendente. El dualismo entre este mundo y el otro, resultado de la imperfección del hombre, desaparecería. Lo ideal sería lo real. Si se pudiera conocer el orden absolutamente justo cuya existencia es afirmada

6 En su crítica de la doctrina platónica de las Ideas (*Metaphysica*, 900 b.) dice Aristóteles: "Aquellos que ponen las ideas como causas, tratando de descubrir las de las cosas que nos rodean, introdujeron otras iguales en número a éstas, como si un hombre que quisiera contar las cosas pensara que no podría hacerlo mientras fueran pocas y tratara de contarlas después de haber añadido otras a su número. Pues las formas son prácticamente tantas como las cosas o no menos que ellas..."

por la doctrina del derecho natural, el derecho positivo resultaría superfluo, es más, no tendría ningún sentido. Frente a la existencia de un ordenamiento justo de la sociedad, fundado en la naturaleza, en la razón o en la voluntad divina, la actividad de los legisladores positivos sería comparable al esfuerzo de quienes pretendiesen realizar una iluminación artificial a la luz del sol. Si fuera posible resolver el problema de la justicia en la forma en que somos capaces de resolver los de la técnica de la ciencia natural o de la medicina, apenas se pensaría en regular las relaciones entre los hombres por medio de medidas autoritarias de coacción, así como en la actualidad a nadie se le ocurre prescribir coactivamente, a través del derecho positivo, en qué forma deba construirse una máquina de vapor o curarse determinada enfermedad. Si existiera una justicia objetivamente cognoscible, no habría derecho positivo y, por tanto, no existiría el Estado; pues ninguna necesidad habría de constreñir a la gente a ser feliz. La usual afirmación de que existe realmente un orden natural absolutamente bueno, pero trascendente y por tanto no inteligible, o la de que hay un objeto que se llama justicia, pero que no puede ser claramente definido, encierra una contradicción flagrante. De hecho no es sino una frase eufemística para expresar la lamentable circunstancia de que la justicia es un ideal inaccesible al conocimiento humano.

4. Justicia y paz.

La justicia es un ideal irracional. Por indispensable que sea desde el punto de vista de las voliciones y de los actos humanos, no es accesible al conocimiento. Considerada la cuestión desde el punto de vista del conocimiento racional, sólo existen intereses y, por ende, conflictos de intereses. La solución de tales conflictos sólo puede lograrse por un orden que o bien satisfice uno de los intereses en perjuicio del otro, o bien trata de establecer una transacción entre los opuestos. El que sólo uno de esos órdenes sea "justo" es algo que no puede establecerse por un conocimiento racional. El conocimiento sólo puede revelar la existencia de un orden positivo, evidenciada por una serie de actos objetivamente determinables. Tal orden es el derecho positivo. Sólo éste puede ser objeto de la ciencia; y sólo él constituye el objeto de una teoría pura del derecho que no sea metafísica, sino ciencia jurídica. La teoría jurídica pura presenta al derecho como es, sin defenderlo llamándolo justo, ni condenarlo llamándolo injusto. Inves-

tiga el derecho real y posible, no el derecho perfecto. En este sentido es una teoría radicalmente realista y empírica. Se rehúsa a hacer una valoración del derecho positivo.

Hay, sin embargo, una afirmación que en el orden de la experiencia puede ser hecha por la teoría, a saber: únicamente un orden jurídico que no satisficiera los intereses de uno en perjuicio de los de otro, sino que estableciera entre los intereses contrapuestos un compromiso, a fin de reducir al mínimo las fricciones posibles, puede aspirar a una existencia relativamente larga. Sólo un orden de este tipo se hallaría en condiciones de asegurar a los sometidos a él una paz social sobre bases relativamente permanentes. Y aun cuando el ideal de justicia en el sentido originario aquí desenvuelto es algo enteramente distinto del ideal de paz, existe una clara tendencia a identificar los dos ideales o, cuando menos, a substituir el de paz por el de justicia.

5. Justicia y legalidad.

Este cambio de significación del concepto de la justicia corresponde paralelamente a la tendencia a sustraer el problema de la justicia del inseguro reino de los juicios subjetivos de valor, para establecerlo sobre la firme base de un orden social dado. "Justicia" en este sentido significa legalidad; "justo" es que una regla general sea efectivamente aplicada en aquellos casos en que, de acuerdo con su contenido, debe aplicarse. "Injusto" sería que la regla fuese aplicada en un caso y dejase de aplicarse en otro similar. Y esto parece "injusto" independientemente de cuál sea el valor intrínseco de la regla general cuya aplicación es examinada. Justicia, en el sentido de legalidad, es una cualidad que no se refiere al contenido de un orden positivo, sino a su aplicación. En este sentido, la justicia es compatible con un orden jurídico positivo y exigida por él, ya se trate de un sistema capitalista o comunista, democrático o autocrático. "Justicia" significa subsistencia de un orden jurídico a través de una consciente aplicación del mismo. Se trata de la justicia "bajo el derecho". La afirmación de que la conducta de un individuo es "justa" o "injusta" en el sentido de "legal" o "ilegal", significa que su comportamiento corresponde o no a una norma jurídica que el sujeto que juzga presupone como válida, en cuanto pertenece a un orden jurídico positivo. Tal aserto tiene lógicamente el mismo carácter que aquel por el cual subsumimos un fenómeno concreto bajo un concepto abstracto. Si la afirmación de que cierta conducta corresponde o no a una

norma jurídica es llamada juicio de valor, entonces este será un juicio objetivo de valor que tendrá que ser claramente distinguido del juicio subjetivo mediante el cual expresa un deseo o un sentimiento el sujeto que juzga. La afirmación de que determinada conducta es legal o ilegal es independiente de los sentimientos y deseos del que juzga, y puede ser verificada en una forma objetiva. Solo en el sentido de legalidad puede el concepto de la justicia entrar en el ámbito de la ciencia jurídica.⁷

B) EL CRITERIO DEL DERECHO. (EL DERECHO COMO UNA TÉCNICA SOCIAL ESPECÍFICA)

Si limitamos nuestra investigación al derecho positivo y comparamos todos los ordenamientos sociales, pasados y presentes, a los que generalmente se da el nombre de "derecho", descubriremos que tienen una característica común, que los órdenes sociales de otra clase nunca presentan. Esta característica constituye un hecho de importancia suprema para la vida social y su estudio científico. Y tal característica es el único criterio por el cual podemos distinguir claramente el derecho de otros fenómenos sociales, como la moral y la religión. ¿Cuál es ese criterio?

a) Motivación directa e indirecta

Es función de todo orden social, de toda sociedad —ya que la sociedad no es sino un orden social— provocar cierta conducta recíproca de los seres humanos: hacer que se abstengan de determinados actos que por alguna razón se consideraran perjudiciales a la sociedad, y que realicen otros que por alguna razón repúntanse útiles a la misma.

De acuerdo con la forma en la cual se lleva a cabo la conducta social deseada, pueden distinguirse varios tipos de órdenes sociales. Estos tipos —entiéndase que los que aquí queremos presentar son tipos ideales— hallanse caracterizados por la motivación específica utilizada por el orden social para inducir a los individuos a comportarse en la forma que se desea. La motivación puede ser directa o indirecta. El orden puede enlazar ciertas ventajas a su observancia y ciertos perjuicios a su inobservancia y, por tanto, convertir el deseo de las ventajas prometidas o el temor de los perjuicios con que se amenaza, en un motivo determinante del comportamiento. La

⁷ Cf. *infra*, p. 56.

conducta conforme al orden establecido es ejecutada a través de una sanción estipulada por el mismo orden. El principio de la recompensa y el castigo —o principio de retribución—, fundamental para la vida social, consiste en ligar la conducta que se ajusta al orden establecido y la contraria a éste, con la ventaja prometida o con el perjuicio objeto de la amenaza, considerados como sanciones.

El orden social puede, sin embargo, incluso sin prometer una recompensa en caso de obediencia y sin amenazar con un mal en caso de desobediencia, esto es, sin decretar sanciones, exigir la conducta que aparece directamente a los individuos como ventajosa, de tal manera que la simple representación de una norma que decreta tal conducta sea suficiente como motivo para el comportamiento reclamado. Este tipo de motivación directa rara vez se encuentra en la realidad social en toda su pureza.

En primer lugar, apenas hay normas cuyo contenido apele directamente a los individuos cuya conducta regula, en forma tal que la mera representación de este contenido baste para determinar la conducta. Además, la conducta social de los individuos se halla siempre acompañada por un juicio de valor, a saber: la idea de que la conducta en concordancia con el orden es "buena", mientras que la contraria al mismo es "mala". De aquí que la conformidad con el orden se ponga normalmente en conexión con la aprobación de los actos del prójimo y la no conformidad con la censura de tales actos. El efecto de esta reacción del grupo frente a la conducta de los individuos conforme o contraria al orden, es una sanción del mismo orden. Desde un punto de vista realista, la diferencia decisiva no radica entre órdenes sociales cuya eficacia se basa en sanciones y órdenes sociales cuya eficacia no se basa en ellas. Cada orden social se encuentra en alguna forma "sancionado" por la reacción específica de la comunidad frente a la conducta de sus miembros conforme o contraria al orden. Lo anterior vale también para sistemas morales altamente desarrollados que en forma más perfecta se aproximan al tipo de la motivación directa por normas no sancionadas. La única diferencia es que ciertos órdenes sociales establecen sanciones definidas, mientras que, en otros, las sanciones consisten en una reacción automática de la comunidad no señalada expresamente por el orden en cuestión.

b) *Sanciones trascendentes y sanciones socialmente organizadas*

Las sanciones estipuladas por el orden social pueden tener un carácter trascendente, esto es, religioso, o un carácter social immanente.

En el primer caso las señaladas por el orden consisten en ventajas o desventajas que deben ser aplicadas a los individuos por una autoridad sobrehumana, por un ser caracterizado más o menos como divino. De acuerdo con la idea que los individuos tienen de los seres sobrehumanos, en los comienzos del desenvolvimiento religioso, esos seres no existen en un más allá diferente de este mundo, sino que se encuentran estrechamente ligados con los hombres en la naturaleza circundante. El dualismo del más allá y de este mundo no es conocido todavía para el hombre primitivo.⁸ Sus primeros dioses son probablemente las almas de los muertos, particularmente de sus antepasados, que viven en árboles, ríos, rocas y, especialmente, en ciertos animales. Son ellos quienes garantizan el mantenimiento del orden social primitivo al castigar su violación con la muerte, la enfermedad, la falta de suerte en la cacería y en otras formas semejantes, y al recompensar su observancia con la salud, la longevidad y la fortuna en la caza. La retribución emana de la divinidad pero se realiza en este mundo. El hombre primitivo explica la naturaleza de acuerdo con el principio de retribución. Considera los acontecimientos naturales sólo en relación con las ventajas o desventajas ligadas a esos acontecimientos, o interpreta los hechos ventajosos como recompensa, los desventajosos como castigo que le es impuesto por los seres personales y sobrehumanos a quienes imagina existentes dentro o detrás de los fenómenos naturales. El orden social más primitivo tiene un carácter completamente religioso. Originariamente no conoce más sanciones que las religiosas, es decir, las que emanan de una autoridad sobrenatural. Sólo más tarde, al menos dentro del grupo más restringido, aparecen al lado de las sanciones trascendentes otras que tienen un carácter social immanente, esto es, organizado, y cuya ejecución se encomienda a un individuo determinado por el orden social y de acuerdo con las normas del mismo. En las relaciones entre grupos diferentes, la venganza de la sangre aparece en época muy remota como una reacción socialmente organizada contra ofensas que se consideran injustificadas y que son imputables a un miembro de un grupo extraño.

El grupo del cual proviene la reacción es una comunidad basada en relaciones de parentesco. La reacción es provocada por temor al alma de la persona asesinada. Se piensa que la víctima no puede vengarse por sí misma de su asesino si éste pertenece a un grupo extraño. Por ello construye a sus pacientes a ejecutar la venganza. La sanción socialmente organizada en la forma que se acaba de indicar, se halla garantizada, a su vez, por una san-

8 Cf. mi *Society and Nature* (1943), pp. 24 ff.

ción trascendente. Aquellos que dejan de vengar la muerte de su pariente en la persona del asesino extranjero y de su grupo, son amenazados con la enfermedad y con la muerte por el alma del asesinado. Parece que la venganza de la sangre es la más antigua de las sanciones socialmente organizadas. Conviene advertir que originalmente tenía un carácter intertribal. Únicamente cuando la comunidad social comprende varios grupos basados en relaciones de parentesco, la venganza de la sangre se convierte en una institución intra-tribal.

En el desenvolvimiento ulterior del desarrollo religioso, la divinidad es concebida dentro de un reino completamente distinto de este mundo y muy lejano a él, y la realización de la retribución divina es relegada al más allá. Muy a menudo este más allá es dividido —de acuerdo con el doble carácter de la retribución— en un cielo y un infierno. En esta etapa, el orden social ha perdido su carácter religioso. El orden religioso funciona solamente como un suplemento y soporte del social. Las sanciones del último son exclusivamente actos de individuos humanos regulados por el mismo orden social.

c) *Castigo y recompensa*

Es un hecho digno de ser subrayado que, de las dos sanciones que hemos presentado aquí como típicas —la desventaja con que se amenaza para el caso de desobediencia (castigo en el sentido más amplio del término) y la ventaja prometida para el caso de obediencia (recompensa)—, la primera desempeña en la realidad social un papel mucho más importante que la segunda. Que la técnica del castigo es preferida a la de la recompensa se advierte con claridad especial cuando el orden social tiene todavía un carácter esencialmente religioso, es decir, cuando está garantizado por sanciones trascendentes. La conducta de los pueblos primitivos conforme al orden social y, sobre todo, la obsecrancia de las numerosas prohibiciones llamadas "tabús", encuentrase principalmente determinada por el temor que domina la vida de tales pueblos. Es el temor del grave daño con el cual la autoridad sobrehumana reacciona contra cada violación de las costumbres tradicionales. Si las violaciones de las normas sociales son mucho menos frecuentes en las sociedades primitivas que en las civilizadas, como algunos etnólogos lo afirman, el responsable de este efecto de preservación del orden social es principalmente el temor a la venganza de los espíritus, castigo de origen divino, pero que tiene lugar en el mundo. La esperanza de una recompensa posee sólo un significado secundario. E incluso en religiones

más altamente desarrolladas, donde la retribución divina no se realiza ya o no se realiza únicamente en este mundo sino en el otro, la idea de un castigo para después de la muerte ocupa el primer plano. En las creencias actuales de la humanidad el miedo al infierno se encuentra mucho más vivo, y la imagen de un lugar de expiación es mucho más concreta que la esperanza usualmente muy vaga de un paraíso en donde nuestra virtud encontrará su recompensa. Incluso cuando la fantasía de los individuos no se halla limitada, en relación con la satisfacción de sus deseos, por restricciones de ninguna especie, imaginan aquellos un orden trascendente cuya técnica no es enteramente distinta de la de la sociedad empírica.

Esto puede deberse al hecho de que la ideología religiosa refleja siempre en forma más o menos intensa la realidad social efectiva. Y por lo que toca a la organización del grupo, únicamente es tomado en cuenta de manera esencial un método para lograr la conducta socialmente deseada: la amenaza y la aplicación de un mal en caso de la conducta contraria; esto es, la técnica del castigo. La de la recompensa desempeña un papel importante sólo en las relaciones privadas entre individuos.

d) *El derecho como, orden coercitivo*

El daño aplicado al violador del orden cuando la sanción está socialmente organizada, consiste en la privación de ciertas posesiones: vida, salud, libertad o propiedad. Como las posesiones le son quitadas contra su voluntad, esta sanción tiene el carácter de medida coercitiva. Lo anterior no significa que al aplicar la sanción tenga que hacerse uso de la fuerza física. Ello es necesario únicamente en el caso de que al aplicarse la sanción haya resistencia del sujeto sancionado. Si la autoridad que aplica la sanción tiene un poder adecuado, tal cosa ocurre sólo excepcionalmente. Un orden social que trata de provocar la conducta deseada mediante el establecimiento de esas medidas recibe el nombre de orden coactivo. Tiene este carácter porque amenaza los actos socialmente dañosos con medidas coercitivas y aplica tales medidas. Como tal, difiere de todos los otros órdenes sociales posibles — aquellos que establecen la recompensa más bien que el castigo como sanción y, especialmente, los que no establecen sanciones en absoluto y descansan en la técnica de la motivación directa. En contraste con los órdenes que establecen medidas coercitivas como sanciones, la eficacia de los demás no se apoya en la coacción, sino en la obediencia voluntaria. Este contraste no es sin embargo tan claro como pudiera parecer a primera vista.

Ello se debe al hecho de que la técnica de la recompensa, como técnica de motivación indirecta, ocupa un lugar intermedio entre la técnica de motivación indirecta a través del castigo, técnica de coacción, y la técnica de la motivación directa, que supone la obediencia voluntaria. La obediencia voluntaria es por sí misma una forma de motivación, esto es, de coacción, y, por tanto, desde el punto de vista psicológico no es libertad, sino coacción. Si los órdenes coactivos son comparados con aquellos que no tienen tal carácter sino que descansan en la obediencia voluntaria, tal cosa sólo es posible en el sentido de que unos establecen como sanciones medidas de coacción, en tanto que los otros no lo hacen. Y estas sanciones son medidas coactivas únicamente en cuanto los individuos de que se trate son privados contra su voluntad de ciertas posesiones y, si es necesario, mediante el empleo de la fuerza física. En este sentido el derecho es un orden coactivo.

Si llamamos ordinariamente jurídicos a todos esos órdenes sociales, tan extraordinariamente diferentes en sus contenidos, que han prevalecido en diferentes épocas y entre los pueblos más diversos, podría suponerse que estamos empleando una expresión casi desprovista de sentido. ¿Qué puede tener en común el llamado derecho de los antiguos babilonios con el que existe actualmente en los Estados Unidos? ¿Qué puede tener en común el orden social de una tribu negra sometida a un cacique despótico —orden al que también se da el nombre de derecho— con la Constitución de la República Suiza? Hay sin embargo un elemento común que justifica plenamente tal terminología y permite a la palabra "derecho" aparecer como expresión de un concepto que tiene un significado social altamente importante. Pues la palabra se refiere a esta técnica social específica de un orden coactivo que, pese a las grandes diferencias entre el derecho de la Babilonia antigua y el de los Estados Unidos en la actualidad o entre el de los Ashanti en África occidental y el de Suiza en Europa, es, sin embargo, esencialmente el mismo para todos estos pueblos, tan diversos desde el punto de vista del tiempo, del lugar y de la cultura, a saber: la técnica social que consiste en provocar la conducta socialmente deseada a través de la amenaza de una medida coercitiva que debe aplicarse en caso de un comportamiento contrario. Cuestión sociológica muy importante es la que estriba en saber cuáles son las condiciones sociales que hacen necesaria esta técnica. Ignoro si podemos contestar satisfactoriamente tal pregunta. Tampoco sé si es posible a la humanidad emanciparse totalmente de tal técnica social. Pero si el orden social no hubiera de tener ya en el futuro el carácter de un orden coactivo y la sociedad pudiera existir sin "derecho", entonces

la diferencia entre la sociedad del futuro y la de nuestra época sería incommensurablemente mayor que la que hay entre los Estados Unidos y la Babilonia antigua o entre Suiza y la tribu de los Ashanti.

e) *Derecho, moralidad y religión*

Al reconocer al derecho como la técnica social específica de un orden coactivo, podemos distinguirlo netamente de otros órdenes sociales que en parte tienen los mismos fines que el derecho, si bien los persiguen por medios enteramente diversos. El derecho es un medio, un medio social específico, no un fin. Tanto el derecho como la moral y la religión prohíben el asesinato. Pero el derecho lo hace estableciendo que si un hombre comete el delito de homicidio, entonces otro hombre, designado por el orden jurídico, deberá aplicar en contra del homicida una cierta medida de coacción prescrita por el mismo orden. La moral se limita por su parte a decirnos "No matarás". Y si un asesino sufre ostracismo moral de parte de su prójimo, y más de un individuo se abstiene de matar no tanto porque quiere evitar la sanción del derecho, sino porque teme la desaprobación moral de sus semejantes, en todo caso subsiste una diferencia esencial: la de que la reacción del derecho consiste en una medida coactiva impuesta por el orden y socialmente organizada, mientras que la reacción moral contra la conducta contraria a las normas éticas no está establecida por el orden moral, ni, en caso de existir, se halla socialmente organizada. Desde este punto de vista, las normas religiosas se encuentran más próximas a las jurídicas que las de la moral. Pues las religiosas amenazan al asesino con el castigo de una autoridad sobrehumana. Pero las sanciones establecidas por tales normas tienen un carácter trascendente: no el de sanciones socialmente organizadas, ni siquiera cuando es el orden religioso el que las establece. Probablemente son más efectivas que las jurídicas. Su eficacia, sin embargo, presupone la creencia en la existencia y en el poder de una autoridad sobrehumana.

No es, sin embargo, la eficacia de las sanciones lo que está en cuestión, sino únicamente saber si son establecidas, y en qué forma, por el orden social. La sanción socialmente organizada es un acto coercitivo que un individuo determinado por el orden social dirige, en la forma establecida por el mismo orden, contra el responsable de la conducta contraria al propio orden. A esta conducta le damos el nombre de "acto antijurídico". Tanto el acto antijurídico como la sanción, encuéntranse determinados por

el orden jurídico. La sanción es la reacción de dicho orden contra el acto anti-jurídico, o lo que equivale a lo mismo, la reacción de la comunidad, constituida por el orden jurídico, frente al violador del propio orden. El individuo que ejecuta la sanción obra como un agente del orden jurídico. Esto equivale a decir que la persona que ejecuta la sanción actúa como órgano de la comunidad constituida por ese orden. Una comunidad social no es otra cosa que el orden social que regula la conducta mutua de los individuos sometidos al mismo. Decir que determinados individuos pertenecen a cierta comunidad, o forman cierta comunidad, significa solamente que se encuentran sujetos a un orden común que regula su conducta recíproca. La sanción jurídica es de este modo interpretada como un acto de la comunidad jurídica; mientras que la sanción trascendente —enfermedad o muerte del pecador o castigo en el otro mundo— nunca se interpreta como reacción de un grupo social, sino siempre como acto de una autoridad sobrehumana y, por ende, superior a la autoridad social.

f) Monopolio del uso de la fuerza

Entre las paradojas de la técnica social que hemos caracterizado como orden coactivo se encuentra el hecho de que su instrumento específico, el acto coercitivo de la sanción, es exactamente de la misma especie que el que trata de prevenir en las relaciones de los individuos, esto es, el acto anti-jurídico; pues la sanción contra la conducta perjudicial a la sociedad es también conducta. Aquello que debe obtenerse mediante la amenaza de una privación forzada de la vida, la salud, la libertad o la propiedad, es precisamente que los hombres en su actividad recíproca se abstengan de privarse por la fuerza uno a otro de la vida, la salud, la libertad o la propiedad. La fuerza es empleada para prevenir el empleo de la fuerza en la vida social. Esto parece ser una antinomia; y el esfuerzo para evitarla conduce a la doctrina del anarquismo absoluto, que proscribe la fuerza, incluso como sanción. El anarquismo tiende a establecer el orden social exclusivamente sobre la base de la obediencia voluntaria de los individuos. Tal doctrina rechaza la técnica de un orden coercitivo y, por tanto, repudia al derecho como forma de organización.

Sin embargo, la antinomia sólo es aparente. El derecho es, sin duda alguna, un orden establecido para promover la paz, ya que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones de los miembros de la comunidad. Empero, no excluye de manera absoluta su empleo. El derecho y la fuerza no deben ser

entendidos como absolutamente incompatibles entre sí. Aquel es la organización de ésta. Pues el primero señala ciertas condiciones al uso de la fuerza en las relaciones entre los hombres, autorizando el empleo de ésta únicamente por ciertos individuos y en determinadas circunstancias. El derecho permite formas de conducta que, en otras circunstancias, tendrían que considerarse como "prohibidas"; en la inteligencia de que jurídicamente prohibido quiere decir aquello que constituye la condición para la imposición de un acto coactivo, con el carácter de sanción. El individuo que, autorizado por el orden jurídico, aplica la medida coactiva (la sanción), obra como un agente de éste, o —lo que equivale a lo mismo— como órgano de la comunidad constituida por tal orden. Únicamente ese individuo, únicamente el órgano de la comunidad, está autorizado para emplear la fuerza. Podría decirse, en consecuencia, que el derecho hace del uso de la fuerza un monopolio de la comunidad. Y precisamente al proceder así, pacifica a ésta.

g) Derecho y paz

La paz es el estado en el que no se hace uso de la violencia. En este sentido de la palabra el derecho procura sólo una paz relativa, no absoluta, ya que priva al individuo del derecho de emplear la fuerza, pero reserva a la comunidad tal derecho. La paz del derecho no es una condición de absoluta ausencia de fuerza; un estado de anarquía, sino una condición de monopolio de la fuerza, un monopolio de ésta en favor de la comunidad.

En última instancia, una comunidad sólo es posible si cada individuo respeta ciertos intereses —vida, salud, libertad y propiedad de los demás—, es decir, si cada uno se abstiene de interferir violentamente en las esferas de interés de los otros. La técnica social que llamamos "derecho" consiste en inducir al individuo a abstenerse de la interferencia violenta en la esfera de intereses de los otros, gracias al empleo de un medio específico: si tal interferencia existe, la comunidad jurídica reacciona interfiriendo en la esfera de intereses del responsable de la interferencia previa. Ojo por ojo. La idea de la retribución se encuentra en la base de esta técnica social. Solamente en un estado relativamente avanzado de la evolución aquella idea es substituida por la de prevención. Pero entonces sólo se opera un cambio en la ideología que justifica la técnica específica del derecho. La técnica sigue siendo la misma.

De este modo la interferencia violenta en la esfera de intereses de otra persona constituye por una parte un acto antijurídico y, por otra, una sanción.

El derecho es el orden de acuerdo con el cual el uso de la fuerza es generalmente prohibido, pero excepcionalmente, bajo ciertas circunstancias y para ciertos individuos, permitido como sanción. En la proposición jurídica, el empleo de la fuerza aparece ya como acto antijurídico, esto es, como condición de la sanción, o como sanción, es decir, como reacción de la comunidad jurídica contra el acto violatorio.

En cuanto la interferencia coactiva en la esfera de los intereses de los individuos sólo se permite como reacción de la comunidad contra la conducta prohibida, tal interferencia es convertida en un monopolio de la comunidad, con lo cual determinada esfera de intereses de los individuos resulta protegida. Mientras no existe un monopolio de la comunidad para la interferencia coactiva en la esfera de intereses del individuo, esto es, mientras el orden social no estipula que tal interferencia únicamente puede efectuarse en ciertas condiciones claramente definidas (a saber: como reacción contra la interferencia ilegal en la esfera de esos mismos intereses y sólo por los individuos señalados al efecto), no cabe hablar de una esfera de intereses protegida por el orden social. En otras palabras: no hay —en el sentido que aquí hemos expuesto— una situación de derecho, que es, esencialmente, una situación de paz.

h) *Coacción psíquica*

La opinión de que la coacción es un elemento esencial al derecho es a menudo falsamente interpretada, cuando se afirma que la efectividad de la sanción jurídica es una parte del concepto del derecho. Se dice, que la sanción es efectiva cuando los individuos sometidos al derecho se comportan "legalmente", a fin de evitar el daño de la sanción. También se habla de la efectividad de la sanción cuando ésta es ejecutada al realizarse su supuesto, el acto antijurídico. Una expresión de este punto de vista es el aserto tan frecuentemente repetido de que el derecho es una norma "coercible", o inclusive una norma que es efectivamente impuesta de modo "coactivo" por determinada autoridad. Típica a este respecto es la muy conocida definición propuesta por Holland: "Ley, en el sentido propio del término es... una regla general de la acción humana externa sancionada por una autori-

dad política soberana."⁹ Es decir, es de la esencia de la regla jurídica que la sanción que prescribe sea ejecutada por el órgano correspondiente. Pero este es el caso únicamente cuando un individuo no se comporta de acuerdo con la ley, es decir, cuando "viola" la norma jurídica. En otras palabras, la sanción que debe ser ejecutada por el órgano es establecida sólo para aquellos casos concretos en que la conducta que el orden legal pretende provocar no ha sido "ejecutada" y, por ende, se ha revelado como susceptible de no ser "ejecutada". Y la sanción se establece únicamente para este caso.

Usamos el término "súbdito" para designar el individuo que obedece o deja de obedecer la ley, y el término "órgano" para el que ejecuta la sanción y al ejecutarla aplica la ley. Si el derecho es definido como una norma coercible de la conducta humana, entonces tiene que hacerse una distinción entre la conducta del súbdito y la del órgano. En su definición Holland parece referirse a la conducta del órgano. Sin embargo, aquellos que hablan de la "coerción" jurídica por regla general tienen presente la conducta del súbdito: el hecho de que éste es compelido a obedecer la norma jurídica. Refiérense, no a la medida coactiva que el órgano efectivamente ejecuta, sino al temor del súbdito de que en caso de desobediencia, es decir, en caso de una conducta antijurídica, esta medida sea tomada. La "coerción" que tienen presente es pues una compulsión psíquica, nacida de la idea que los hombres se forman del orden jurídico. Esta idea es "coercitiva" si procura un motivo para la conducta descaída por el orden jurídico. En la medida en que existe esta compulsión psíquica, el derecho no difiere de las normas morales o religiosas. Pues tales normas son también coercitivas en la medida en que la representación de las mismas nos hace conducirnos de acuerdo con ellas.

i) *Los motivos de la conducta conforme al derecho*

El intento de convertir esta "compulsión psíquica" en un elemento esencial del concepto del derecho está expuesto a otra objeción grave. No conocemos exactamente qué motivos inducen a los hombres a cumplir las normas jurídicas. Ningún orden jurídico positivo ha sido nunca investigado en una forma científica satisfactoria con el propósito de responder a esta pregunta. En la actualidad ni siquiera tenemos a nuestra disposición méto-

⁹ Sir Thomas Erskine Holland, *The Elements of Jurisprudence* (13 th. ed., 1924), 41 f.

dos que nos capaciten para tratar de una manera científica, desde los puntos de vista sociológico y político, un problema tan extraordinariamente importante. Lo único que podemos hacer son conjeturas más o menos plausibles. Muy probablemente, sin embargo, los motivos de la conducta conforme al derecho no son únicamente el temor a las sanciones jurídicas o incluso la creencia en la fuerza obligatoria de las normas de aquel. Cuando las ideas morales y religiosas en un individuo corren paralelamente al orden jurídico a que él mismo está sometido, su conducta jurídica se debe a menudo a estas ideas morales y religiosas. También pueden ser un motivo para obrar de acuerdo con el derecho ciertos beneficios que en modo alguno están determinados por el orden jurídico, pero que se encuentran de hecho en conexión con la conducta jurídica. Muy a menudo un hombre cumple el deber jurídico de pagar las deudas que tiene, no porque desee evitar la sanción establecida por la ley contra la persona que no paga sus deudas, sino porque sabe que si las paga cuidadosamente su crédito aumentará, en tanto que si no las paga, perderá éste. La ventaja del crédito no es establecida por el orden jurídico como recompensa por el cumplimiento de los propios deberes. Es un beneficio ligado de hecho a la conducta conforme a la ley, y el deseo de obtener tal beneficio es a menudo el motivo de dicha conducta. Del hecho de que en gran medida la gente se comporta de acuerdo con las normas jurídicas, sería indebido concluir que ello se debe a la compulsión psíquica que la idea del orden jurídico, el temor a sus sanciones, ejerce sobre las personas. Decir que un orden jurídico es "eficaz" significa simplemente que la conducta de la gente se ajusta a dicho orden. Con ello nada se afirma acerca de los motivos de tal conducta ni, en particular, sobre la "compulsión psíquica" que pueda emanar del orden jurídico.

j) Argumentos contra la definición del derecho como orden coercitivo

1. La teoría de Eugen Ehrlich.

La doctrina según la cual la coacción es un elemento esencial al derecho es muy a menudo combatida, especialmente desde un punto de vista sociológico. El argumento típico es la referencia al hecho de que los hombres obedecen el orden jurídico y en muchos casos —si no en la mayoría de ellos— cumplen sus deberes jurídicos, no por temor a las sanciones establecidas por el mismo orden, sino por razones distintas. Así, por ejemplo, Eu-

gen Ehrlich, uno de los fundadores de la Sociología del Derecho, dice lo siguiente:

"Es enteramente obvio que cada hombre vive en innumerables relaciones jurídicas, y que, con pocas excepciones, cumple de manera completamente voluntaria los deberes que en virtud de esas relaciones le corresponden." Cada uno cumple sus propios deberes como padre o hijo, como marido o mujer, se abstiene de interferir en el goce del vecino sobre su propiedad, paga sus propias deudas, entrega lo que ha vendido y realiza en favor de su patrón la prestación a que se había obligado. El jurista se conforma con decir que los hombres cumplen sus deberes únicamente porque saben que los tribunales pueden eventualmente construírlos al cumplimiento. Si se tomara un trabajo al cual realmente no está acostumbrado, de observar lo que los hombres hacen y dejan de hacer, pronto se convencería de que, por regla general, el pensamiento de una coacción ejercida por los tribunales ni siquiera les pasa por la mente. En la medida en que no obran, lo que constituye el caso usual, sólo de una manera instintiva, su conducta se encuentra determinada por motivos completamente diversos: si se construíeran de otro modo podrían tener disputas con sus parientes, perder su posición o su clientela, o adquirir reputación de pendencieros, deshonestos o irresponsables. El jurista, menos que nadie, debería pasar por alto el hecho de que lo que en este sentido los hombres hacen o dejan de hacer es enteramente diferente y a veces mucho más de lo que las autoridades pudieran construírlos a hacer o a omitir. Con no poca frecuencia, la norma de conducta es enteramente diversa de aquella que es obedecida por temor a la coacción (*Zwangsnorm*)."¹⁰

La afirmación de que los individuos sometidos al orden jurídico no ajustan únicamente su conducta a este orden porque quieren evitar los desagradables efectos de las sanciones establecidas por el mismo, es indudablemente correcta. Pero tal afirmación no es en modo alguno inconciliable con la doctrina según la cual la coacción es un elemento esencial al derecho. Esa doctrina no se refiere a los motivos reales de la conducta de los individuos sometidos al orden jurídico, sino al contenido de éste, a los medios específicos usados por dicho orden para provocar un cierto comportamiento de los obligados, es decir, a la técnica específica del mismo. La doctrina de que la coacción es un elemento esencial al derecho no se refiere a la conducta efectiva de los individuos sometidos al orden jurídico, sino a este

¹⁰ Eugen Ehrlich, *Grundlegung der Soziologie des Rechts* (1913); citamos la traducción inglesa, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (1936), 21.

mismo orden, a la circunstancia de que establece sanciones y por este hecho y sólo por él, es decir, por su técnica social específica, se distingue de otros órdenes sociales. Si un individuo se abstiene —contra su impulso instintivo— del homicidio, el adulterio o el robo, porque cree en Dios y se siente ligado por los Diez Mandamientos, no porque tema el castigo que ciertas normas jurídicas enlazan a esos delitos, las normas jurídicas resultan —por lo que a él toca— completamente superfluas. No teniendo eficacia, ni siquiera las podemos considerar, desde un punto de vista psicológico-social, como existentes en relación con tal persona. Si caracterizamos la conducta humana desde el punto de vista de sus motivos, el comportamiento de tal individuo no sería un fenómeno jurídico, sino religioso, y su estudio no correspondería a la sociología del derecho, sino a la de la religión. Si el orden jurídico establece un castigo para el caso de que un hombre cometa homicidio, robo o adulterio, es porque el legislador supone —correcta o incorrectamente— que la creencia en Dios y sus Diez Mandamientos, y otros motivos distintos del temor a la sanción jurídica, no bastan para inducir al individuo a abstenerse de cometer tales delitos.

Si existe un orden jurídico que establece sanciones específicas, es precisamente porque los hombres que lo crean y ejecutan suponen —correcta o incorrectamente— que otros órdenes sociales que establecen sanciones distintas o no establecen ningunas, no son suficientemente eficaces para provocar la conducta que los creadores y ejecutores de aquél consideraran como deseable.

Lo que distingue al orden jurídico de todos los otros órdenes sociales, es el hecho de que regula la conducta humana por medio de una técnica específica. Si ignoramos este elemento específico del derecho, y no lo concebimos como una técnica social específica y lo definimos simplemente como orden y organización, y no como orden (u organización) coercitivo, perderemos la posibilidad de diferenciarlo de otros fenómenos sociales, e identificaremos el derecho con la sociedad, y la sociología jurídica con la sociología general.

Este es un error típico de muchos sociólogos juristas y, especialmente, de la sociología jurídica de Eugen Ehrlich. Su tesis principal es la siguiente: el derecho es un orden coactivo únicamente si lo identificamos con las normas de acuerdo con las cuales los tribunales tienen que decidir las controversias jurídicas sometidas a su conocimiento. Pero el derecho no es, o no es únicamente, la norma de acuerdo con la cual los tribunales deciden o tienen que decidir las contiendas; el derecho es la norma de acuerdo con la cual los hombres efectivamente se conducen:

"La norma de la conducta humana y aquella de acuerdo con la cual los jueces deciden las controversias jurídicas pueden ser dos cosas enteramente distintas; pues los hombres no siempre proceden de acuerdo con los preceptos que serán aplicados para la solución de sus disputas. No hay duda de que el historiador del derecho concibe a éste como una norma de la conducta humana, y establece las normas de acuerdo con las cuales, en la antigüedad y en la Edad Media, se contraía matrimonio, o el marido y la mujer, los padres y los hijos vivían juntos en el seno de la familia; el historiador del derecho dice si la propiedad era individual o común, si el suelo era cultivado por el dueño o por un arrendatario que pagaba una renta, o por un siervo que prestaba determinados servicios; dice también cómo se celebraban los contratos y en qué forma era transmitida la propiedad. Oíríamos lo mismo si preguntásemos a un viajero sobre el derecho de los pueblos que ha conocido. Nos hablaría de costumbres matrimoniales, de la vida familiar, de lo forma de celebración de los contratos; pero poco tendría que decirnos sobre las normas de acuerdo con las cuales los procesos son decididos.

"Este concepto del derecho, que el jurista adopta de manera completamente instintiva cuando estudia, con un propósito puramente científico, el derecho de un país extranjero o de épocas remotas, será abandonado por él cuando se vuelva hacia el derecho positivo de su propio país y de la época a que pertenece. Sin tener conciencia de ello, como secretamente, la norma de acuerdo con la cual los hombres proceden se convierte para él en aquella por la cual sus actos son juzgados por las cortes y otros tribunales. Esta última norma es también, por supuesto, una regla de conducta, pero sólo lo es para una pequeña parte de los individuos, es decir, para las autoridades encargadas de la aplicación del derecho, no como la primera, para la generalidad de la población. La opinión científica ha dejado su lugar al punto de vista práctico, adaptado a las exigencias del funcionario judicial, interesado indudablemente en conocer la norma de acuerdo con la cual tiene que proceder. Es verdad que los juristas consideran también estas normas como normas de conducta, pero llegan a esta conclusión por medio de un salto en su pensamiento. Pretenden decir que las reglas de acuerdo con las cuales los tribunales deciden son aquellas de acuerdo con las cuales los hombres deben regular su conducta. A esto se añade la vaga noción de que en el curso del tiempo los individuos regularán efectivamente su comportamiento de acuerdo con las normas que sirven a los tribunales para emitir sus decisiones. Es verdad que una regla de conducta no es únicamente la regla de acuerdo con la cual los hombres norman consuetudinariamente

su conducta, sino también una regla que les indica cómo deben comportarse; pero es una suposición completamente inadmisible la de que este "deber" se encuentre determinado exclusiva o siquiera preponderantemente por los tribunales. La experiencia cotidiana enseña lo contrario. Seguramente nadie niega que las decisiones judiciales influyen en la conducta de los hombres, pero antes que nada debemos inquirir en qué medida esto es verdadero y de qué circunstancias depende."¹¹

La respuesta de Ehrlich a este problema es que las decisiones judiciales influyen en la conducta de los hombres sólo en una medida muy limitada. Las normas de acuerdo con las cuales los tribunales y otros órganos de la comunidad deciden las controversias, es decir, las normas que establecen actos coactivos como sanciones, son únicamente una parte, y ni siquiera la esencial, del derecho, que es la norma o el complejo de normas de acuerdo con las cuales los hombres—incluyendo a aquellos que no son órganos de la comunidad—efectivamente se conducen. Pero no toda norma de acuerdo con la cual los hombres efectivamente se conducen es jurídica. ¿Cuál es la diferencia específica entre las jurídicas y otras normas de la conducta humana? Es decir: ¿cuál es el criterio del derecho, cuál el objeto específico de una sociología jurídica en contraposición al objeto de la sociología? Para esto Ehrlich tiene solamente la respuesta que sigue: "En consecuencia, tres elementos deben en cualquier circunstancia ser excluidos del concepto del derecho como orden coactivo mantenido por el Estado — concepto al cual la ciencia jurídica tradicional se ha aferrado tenazmente en lo substancial, aun cuando no siempre en la forma. No es un elemento esencial al concepto del derecho que éste sea creado por el Estado; ni que constituya la base para las decisiones de las cortes o de otros tribunales; ni que sea la base de una coacción jurídica fundada en tales decisiones. Queda un cuarto elemento que tendrá que ser el punto de partida, a saber: el derecho es una ordenación... Podemos considerar como establecido que, dentro de la extensión del concepto de asociación, el derecho es una organización, es decir, una norma que asigna a todos y a cada uno de los miembros de la asociación su posición dentro de la comunidad, ya sea de dominación o de sujeción (*Überordnung, Unterordnung*), y sus deberes; y que en la actualidad es completamente imposible suponer que el derecho existe dentro de esas asociaciones principalmente para la realización del propósito de resolver las controversias que surjan en la vida en común. La norma jurídica de acuerdo con la cual son decididas las disputas ante los tribuna-

les, la norma de decisión, es sólo una especie de norma jurídica con funciones y objetos limitados."¹²

El resultado del intento de Ehrlich para emancipar la definición del derecho del elemento de coacción, es la definición siguiente: derecho es una ordenación de la conducta humana. Pero esta es una definición de la sociedad, no del derecho. Cada complejo de normas reguladoras de la conducta recíproca de los hombres es un orden u organización que constituye una comunidad o asociación, y que "asigna a todos y a cada uno de los miembros su posición dentro de la comunidad y sus deberes". Hay muchos órdenes de este tipo que no tienen carácter jurídico. Incluso si limitamos el concepto de orden o de organización a órdenes relativamente centralizados que instituyen órganos especiales para la creación y aplicación del mismo orden, el derecho no queda suficientemente determinado por este concepto. El derecho es un orden que asigna a cada miembro de la comunidad sus deberes y, por ende, su posición dentro de la comunidad, por medio de una técnica específica, estableciendo un acto coactivo, una sanción dirigida contra el individuo que no cumple su deber. Si ignoramos este elemento no podremos diferenciar el orden jurídico de otros órdenes sociales.

2. La serie infinita de sanciones.

Otro argumento contra la doctrina que hace de la coacción un elemento esencial al derecho y declara que las sanciones forman un elemento necesario dentro de la estructura jurídica, es el siguiente: si es necesario garantizar la eficacia de una norma prescribiendo en otra una sanción para el caso de que la primera no sea obedecida, resulta inevitable una serie infinita de sanciones, un *regressus ad infinitum*. Pues "a fin de asegurar la eficacia de una norma de grado *n*, es necesaria una norma de grado *n* más uno".¹³ Como el orden jurídico sólo puede hallarse compuesto por un número limitado de normas, las que establecen sanciones presuponen otras que no las establezcan. La coacción no es un elemento necesario, sino solamente posible del derecho.

La afirmación de que para asegurar la eficacia de una norma de grado *n*, es necesaria otra de grado *n* más uno, por lo cual es imposible asegurar

¹² Ehrlich, *Sociology of Law*, 23-24.

¹³ N. S. Timasheff, *An Introduction to the Sociology of Law* (1939), 264, de acuerdo con L. Petrazsky, *Theory of Law and State* (en ruso: 2ª ed., 1909), 273-285.

la eficacia de todas las jurídicas por medio de otras que establezcan sanciones, es correcta; pero la jurídica no es una norma cuya eficacia esté asegurada por otra que establezca una sanción, aun cuando la eficacia de ésta no esté asegurada por otra regla. Una norma es jurídica no porque su eficacia esté asegurada por otra que establece una sanción; es jurídica en cuanto establece ella misma una sanción. El problema de la coacción (compulsión, sanción) no es un problema de aseguramiento de la eficacia de las normas, sino un problema sobre el contenido de las mismas. El hecho de que sea imposible asegurar la eficacia de todas las de un orden jurídico mediante normas que establezcan sanciones, no excluye la posibilidad de considerar únicamente como jurídicas a las que establecen las sanciones. Todas las de un orden jurídico son coactivas, esto es, normas que establecen sanciones; pero entre éstas hay algunas cuya eficacia no está asegurada por otras normas coactivas. La norma *n*, por ejemplo, dice así: si un individuo roba, otro individuo, órgano de la comunidad, deberá castigar al primero. La eficacia de esta norma está asegurada por la norma *n* más uno: si el órgano no castiga al ladrón, otro órgano debe castigar a aquel que ha violado su deber de castigar al ladrón. No hay una norma *n* más dos que asegure la eficacia de la norma *n* más uno. La coactiva *n* más uno: si el órgano no castiga al ladrón, otro órgano debe castigar a aquel que ha violado la ley, no está garantizada por una norma de grado *n* más dos. Pero todas las de este orden jurídico son normas coactivas.¹⁴

Se objeta finalmente la doctrina de que la coacción es un elemento esencial al derecho, alegando que entre las normas de un orden jurídico hay muchas que no establecen sanciones. Las de la Constitución son frecuentemente señaladas como normas jurídicas, aun cuando no establezcan sanciones. De este argumento hablaremos en un capítulo posterior.¹⁵

C) VALIDEZ Y EFICACIA

El elemento de "coacción" esencial al derecho consiste, entonces, no en la llamada compulsión psíquica, sino en el hecho de que actos específicos de coacción, considerados como sanciones, son establecidos, para casos también específicos, por las reglas que forman el orden jurídico. El elemento de coacción únicamente tiene importancia cuando forma parte del

¹⁴ Esto no significa que la ejecución de la sanción estipulada en una norma jurídica tenga siempre el carácter de un deber jurídico. Cf. *infra*, p. 61.

¹⁵ Cf. *infra*, p. 172.

contenido de la norma jurídica, como acto estipulado por ésta y no como un proceso en la mente del individuo sujeto a la propia norma. Las reglas que constituyen un sistema de moralidad no tienen esta significación. El que los hombres se comporten o no realmente de manera de evitar la sanción con que amenaza la norma jurídica, y el que la sanción sea o no realmente ejecutada en caso de que se llenen las condiciones de ejecución, son cuestiones que atañen a la eficacia del derecho. Pero lo que aquí nos interesa no es la eficacia de éste, sino su validez.

2) La "norma"

¿Cuál es la naturaleza de la validez, en oposición a la eficacia del derecho? La diferencia puede ser ilustrada por un ejemplo: una norma jurídica prohíbe el robo, prescribiendo que todo ladrón debe ser castigado por el juez. Esta regla es "válida" para todas las personas a quienes en esa forma se prohíbe el robo, es decir, los individuos que tienen que obedecer la misma regla, los "súbditos". La norma jurídica es "válida" particularmente para aquellos que realmente roban y al robar "violan" la misma regla. Esto quiere decir que la regla legal vale incluso en aquellos casos en que carece de "eficacia". Precisamente en tales casos es en los que tiene que ser "aplicada" por el juez. La regla en cuestión no sólo es válida para los súbditos sino también para los órganos encargados de aplicar el derecho. Pero conserva su validez aun cuando el ladrón pueda escapar y el juez resulte incapacitado para castigarlo y aplicar la regla. Sin embargo, en el caso particular, ésta es válida para el juez aun cuando carezca de eficacia, ya que las condiciones de la sanción prescrita por la misma regla se han cumplido, a pesar de que aquel se encuentre incapacitado para ordenar la sanción. ¿Cuál puede ser el significado de la afirmación de que la regla es válida aun cuando en un caso concreto carezca de eficacia, es decir, no sea obedecida o no sea aplicada?

Por "validez" entendemos la existencia específica de las normas. Decir que una norma es válida equivale a declarar su existencia o —lo que es lo mismo— a reconocer que tiene "fuerza obligatoria" frente a aquellos cuya conducta regula. Las del derecho son normas en cuanto tienen validez. Son, para hablar de manera más precisa, normas que prescriben una sanción. Pero ¿qué es una norma?

1. El derecho como mandamiento, esto es, como expresión de una voluntad.

En nuestro intento de explicación de la naturaleza de la norma, séanos permitido aceptar provisionalmente que se trata de un mandato. Esta es la forma en que Austin caracteriza al derecho. Dice así el mencionado autor: "Toda *ley* o *regla*... es un *mandato*. O, mejor dicho, las *leyes* o *reglas* en sentido propio son *especies* de mandatos."¹⁶ Un mandato es la expresión de una voluntad (o de un deseo) individual y tiene por objeto la conducta de otro individuo. Si yo quiero (o deseo) que alguien se conduzca en cierta forma y expreso al otro en una determinada forma mi voluntad (o mi deseo), entonces tal expresión de mi voluntad (o de mi deseo) constituye un mandato. Un mandato difiere de una suplica o de un interuego por su forma. En el mandato se expresa en forma imperativa la voluntad de que otra persona se conduzca de una determinada manera. Es particularmente probable que un individuo dé a su voluntad esta forma, cuando tiene o cree tener un cierto poder sobre otro, es decir, cuando está o piensa estar en situación de exigir obediencia. Pero no todo mandato es una norma válida. Un mandato es una norma únicamente cuando obliga al individuo a quien se dirige, o sea, cuando éste debe hacer lo que el mandante reclama. Cuando un adulto ordena a un chiquillo hacer alguna cosa, no es éste un caso de mandato obligatorio, por grande que sea la superioridad del poder del adulto o por imperativa que resulte la forma del mandato. Pero si el adulto es el padre o el maestro del niño, entonces el mandato obliga a éste. El que el mandato sea o no obligatorio depende de que el mandante esté o no "autorizado" para formular el mandato. En caso afirmativo la expresión de su voluntad es obligatoria, aun cuando carezca, de hecho, de un poder superior, y la expresión de su voluntad no revista forma imperativa. Es verdad que Austin opina que "un mandato se distingue de otras expresiones del deseo, no por el estilo en el cual éste es manifestado, sino por el poder y el propósito de la parte que manda, de infligir un daño o una pena en el supuesto de que su deseo no sea atendido." El citado autor añade: "Un mandato se distingue de otras significaciones del deseo en esta peculiaridad, la de que la parte a quien se dirige está expuesta a recibir un daño de la otra en caso de que no haga lo ordenado. Hallarme expuesto a sufrir un daño de parte de usted, si no cumpla el deseo que usted expresa, significa que estoy ligado u obligado por su man-

dato."¹⁷ De este modo identifica los dos conceptos de "mandato" y "mandato obligatorio". Pero esto es incorrecto, pues no todo mandato expedido por un superior en poder es de naturaleza obligatoria. El de un bandido de que le entreguen un dinero, no es obligatorio, aun cuando el bandido se encuentre realmente en condiciones de imponer su voluntad. Reiterémoslo: un mandato es obligatorio no porque el individuo que manda tenga realmente una superioridad de poder sino porque está "autorizado" o "facultado" para formular mandatos de naturaleza obligatoria. Y está "autorizado" o "facultado" únicamente si un orden normativo, que se presupone obligatorio, le concede tal capacidad, es decir, la competencia para expedir mandamientos obligatorios. En este caso, la expresión de su voluntad, dirigida a la conducta de otro individuo, es un mandato obligatorio, incluso cuando el que manda no tiene de hecho un poder real sobre el individuo a quien el mandato se dirige. La fuerza obligatoria de un mandato no "deriva" del mandato mismo, sino de las condiciones en las cuales es formulado. Suponiendo que las reglas jurídicas sean mandatos obligatorios, resulta claro que tienen fuerza obligatoria en cuanto son expedidas por autoridades competentes.

2. La "voluntad" de las partes en una transacción jurídica.

Un análisis más profundo revela, sin embargo, que las reglas del derecho sólo en un sentido muy vago son "mandatos". En el sentido propio de la palabra, un mandato existe únicamente cuando un determinado individuo realiza y expresa un acto de voluntad. En el sentido propio del vocablo, la existencia de un mandato presupone dos elementos: un acto de voluntad que tiene como objeto la conducta de otra persona, y la expresión del mismo acto por medio de palabras, gestos u otros signos. Un mandato sólo existe en cuanto ambos elementos concurren. Si alguien me manda algo y, antes de ejecutar la orden, tengo una prueba satisfactoria de que el acto de voluntad subyacente ha dejado de existir —la prueba puede ser la muerte del mandante— entonces ya no me encuentro colocado frente a ningún mandato, aun cuando la expresión de éste subsista — como ocurriría, por ejemplo, tratándose de un mandato escrito. La situación es totalmente diversa cuando el mandato es obligatorio. Entonces puede decirse que el mandato "subsiste" aun cuando el acto de voluntad haya dejado de existir. La llamada "última voluntad" de una persona, su testamento, es un man-

16 John Austin, *Lectures on Jurisprudence* (5th. ed., 1885), 88.

17 Austin, *Jurisprudence*, 89.

dato que asume fuerza obligatoria al morir el testador, esto es, cuando ya no es capaz de querer, y un mandato, en el sentido propio de la palabra, no puede ya existir. Aquello en lo cual reside en este caso la fuerza obligatoria tiene que ser, por tanto, algo distinto del acto de voluntad del testador. Si un acto real de voluntad de parte del testador es necesario para la validez del testamento, entonces la fuerza obligatoria no puede pertenecer a tal voluntad, sino a algo que es "creado" por ella, y cuya "existencia" o "validez" sobrevive a la existencia de esa voluntad real.

A fin de establecer un "contrato obligatorio", dos individuos tienen que expresar su consentimiento, es decir, su intención concurrente o su voluntad relativa a cierta conducta mutua. El contrato es el producto de la voluntad de las dos partes contratantes. Sin embargo, se supone que aquél conserva su fuerza aun cuando más tarde una de las partes cambie de opinión y deje de querer lo que al celebrarse el contrato dijo que quería. De este modo, el contrato obliga a esa parte incluso contra su voluntad real y, por tanto, la fuerza obligatoria del negocio no puede residir en la voluntad de las partes, ya que tal fuerza obligatoria conserva su "validez" después de que el contrato ha sido concluido. Si designamos con el término "contrato" a aquello que tiene fuerza obligatoria, entonces el contrato obligatorio y el procedimiento por el cual es creado, o sea la expresión del consentimiento de las partes, son dos fenómenos diferentes. Es dudoso, por otra parte, que el procedimiento por el cual el contrato es creado implique necesariamente que en la mente de cada una de las partes haya una intención real, una "voluntad" que tenga por objeto el contenido del contrato.

3. La "voluntad" del legislador.

Si llamamos "mandato" a la ley elaborada por el Parlamento en la forma prescrita por la Constitución o, lo que equivale a lo mismo, si declaramos que constituye la "voluntad" del legislador, entonces ese pretendido mandato apenas tendrá algo en común con un mandato propiamente dicho. Una ley que debe su existencia a una decisión parlamentaria, obviamente no empieza a existir sino en el momento en que la decisión ha sido ya hecha y cuando —suponiendo que sea la expresión de una voluntad— esta última ha dejado de existir. Cuando los miembros del Parlamento han aprobado una ley, vuelven a otras cuestiones y dejan de querer los contenidos de aquélla, supuesto, claro está, que tal voluntad haya existido realmente. Como la ley sólo adquiere existencia al completarse el procedimiento legis-

lativo, esa "existencia" no puede consistir en la voluntad real de los individuos que pertenecen a la asamblea legisladora. El jurista que desea establecer la "existencia" de una ley en modo alguno pretende probar la de fenómenos psicológicos. La "existencia" de una norma jurídica no es un fenómeno psíquico. Un jurista considera una ley como "existente" incluso cuando los individuos que la crearon no quieren ya el contenido de la misma, es más, cuando ya nadie quiere tal contenido, al menos ninguno de los que fueron competentes para crear el precepto legal mediante sus actos de voluntad. De hecho es posible y a menudo realmente ocurre que una ley "exista" en una época en que aquellos que la crearon hace mucho que han muerto y, por tanto, no son ya capaces de ningún acto voluntario. Así pues, la ley obligatoria no puede ser la voluntad de los individuos autores de la misma, incluso cuando para formularla haya sido necesario un acto volitivo real.

Si analizamos psicológicamente el procedimiento por el cual una ley es constitucionalmente creada, descubriremos que el acto creador de la norma obligatoria no tiene que ser necesariamente un acto de "voluntad" que tenga por objeto el contenido del precepto. La ley es creada por una decisión del Parlamento. El Parlamento —de acuerdo con la Constitución— es la autoridad competente para crear la ley. El procedimiento por el cual decide sobre ella consiste esencialmente en votar un proyecto que ha sido sometido al conocimiento de sus miembros. La "decisión aprobatoria" existe cuando la mayoría de los miembros vota por el proyecto. Aquellos que votan en contra no "quieren" el contenido del texto legal. A pesar del hecho de que expresan una voluntad contraria, la manifestación de su voluntad es tan esencial para la creación de la ley como la de aquellos que votan aprobando el proyecto. Es verdad que la ley es la "decisión" de todo el Parlamento, incluyendo la minoría disidente. Pero es obvio que esto no significa que el Parlamento quiera la ley en el sentido psicológico de que cada miembro del mismo desee los contenidos de aquélla. Refirámonos únicamente a la mayoría que vota por la ley. Incluso en este caso, la afirmación de que los miembros de tal mayoría "quieren" la ley es claramente una ficción. Votar por un proyecto en modo alguno implica querer realmente el contenido de la ley. En un sentido psicológico únicamente se puede "querer" aquello de lo que se tiene una representación. Es imposible "querer" algo que se ignora. Pero es un hecho que a menudo, si no siempre, un número considerable de aquellos que votan por un proyecto de ley tienen cuando más un conocimiento muy superficial del contenido de ésta.

Todo lo que exige de ellos la Constitución es que voten por el proyecto levantando sus manos o diciendo "sí". Y esto pueden hacerlo sin conocer el contenido del proyecto o sin haber hecho de tal contenido el objeto de su "voluntad" — en el sentido en que un individuo "quiere" que otro se conduzca de cierta manera cuando le manda hacer tal o cual cosa. No realizaremos el análisis psicológico del hecho de que al discutirse un proyecto de ley un miembro del Parlamento dé la "aprobación" constitucionalmente requerida. Baste decir que el consentimiento para la aprobación de un proyecto no implica necesariamente "querer" el contenido de la ley, y que ésta no es la "voluntad" del legislador — si entendemos por "voluntad" una voluntad real, un fenómeno psicológico—, por todo lo cual la ley no es un mandato en el sentido propio del término.

4. El derecho consuetudinario como mandato.

El carácter ficticio de la afirmación vulgar de que una regla de derecho es un mandato, resulta aún más evidente cuando consideramos el derecho consuetudinario. Supongamos que en una cierta comunidad se considera válida la siguiente regla: un deudor tiene que pagar a su acreedor un interés del 5% en el caso de que no haya ningún convenio sobre este punto. Supóngase, además, que tal regla ha sido establecida a través de la costumbre, y que durante un largo período de tiempo los acreedores han exigido de hecho un interés del 5% y los deudores efectivamente han pagado tal cantidad. Supóngase asimismo que han procedido de esta manera porque tienen la opinión de que tal interés "debe" ser pagado, *opinioe necessitatis*, como decían los juristas romanos.

Sea cual fuere nuestra teoría sobre los hechos creadores del derecho consuetudinario, nunca estaremos en condiciones de afirmar que es "voluntad" o "mandato" de las personas cuya conducta real constituye la costumbre, que cada deudor pague un interés del 5%, en caso de que haya aceptado un préstamo sin haber convenido otro tipo de interés. En cada caso particular ni el acreedor ni el deudor tienen ninguna voluntad en relación con la conducta de otras personas. Un acreedor individual quiere que su deudor le pague el 5% de interés, y este deudor paga realmente a su acreedor el interés reclamado. Esta es la naturaleza de los hechos particulares que en su conjunto constituyen o determinan la existencia de la "costumbre", creando la regla general de que bajo ciertas circunstancias el mutuario tiene que pagar el 5% de interés al mutante. La existencia

de la costumbre no implica ninguna voluntad que tenga como contenido la citada regla. Cuando, en un caso particular, un tribunal de la comunidad condena al deudor a pagar el 5% de interés, tal tribunal basa su fallo en la presunción de que en materia de préstamo se debe proceder en la forma en que los miembros de la comunidad han procedido siempre. Este supuesto no refleja la "voluntad" real de ningún legislador.

5. El "deber ser".

Cuando las leyes son descritas como "mandatos" o expresiones de la "voluntad" del legislador, y se dice del orden jurídico como tal que es el "mandato" o la "voluntad" del Estado, esto tiene que entenderse como una forma figurada de expresión. Como de costumbre, la responsabilidad de la expresión figurativa corresponde a una analogía. La situación que se da cuando una regla de derecho "estipula", "determina" o "prescribe" una cierta conducta humana, es de hecho enteramente análoga a la que existe cuando un individuo quiere que otro se conduzca de tal o cual manera y expresa su voluntad en la forma de un mandato. La única diferencia está en que cuando decimos que una cierta conducta se halla "estipulada", "establecida" o "prescrita" por una regla de derecho, empleamos una abstracción que elimina el acto psicológico de voluntad que se expresa en todo mandato. Si la regla de derecho es un mandato, entonces se trata, por decirlo así, de un mandato no psicológico, de un mandato que no implica una "voluntad" en el sentido psicológico del término. La conducta prescrita por la regla de derecho es "exigida" sin que haya ninguna voluntad humana que "quiera" tal conducta en un sentido psicológico. Esto se expresa diciendo que uno "está obligado a" o "debe" observar la conducta prescrita por el derecho. Una "norma" es una regla que expresa el hecho de que alguien debe proceder de cierta manera, sin que esto implique que otro realmente "quiera" que el primero se comporte de tal modo.

La comparación entre el "deber ser" de una norma y un mandato sólo se justifica en un sentido muy limitado. De acuerdo con Austin, lo que convierte a una ley en "mandato" es su fuerza obligatoria. Es decir, cuando llamamos ley a un mandato expresamos únicamente el hecho de que constituye una "norma". No hay diferencia, en este sentido, entre una ley expedida por un parlamento, un contrato celebrado por dos partes, o un testamento hecho por un individuo. El contrato es también obligatorio, es decir, es una norma que liga a los contratantes. El testamento es igualmente

obligatorio. Es una norma que obliga al ejecutor testamentario y a los herederos. Es dudoso que un testamento pueda, incluso por analogía, ser descrito como "mandato"; y resulta absolutamente imposible describirlo como contrato. En el último supuesto un mismo individuo sería el autor del mandato y encontrarse ligado por él. Ello es imposible, pues nadie puede, hablando propiamente, mandarse a sí mismo. Si es en cambio posible que una norma sea creada por los que están sujetos a ella.

En este punto puede surgir la objeción siguiente: el contrato no liga por sí mismo a las partes; es la ley del Estado la que las obliga a conducirse de acuerdo con el contrato. Sin embargo, algunas veces la ley puede aproximarse mucho al contrato. Es de la esencia de la democracia que las leyes sean creadas por los mismos individuos que resultan obligados por ellas. Como una identidad del que manda con el mandato resulta incompatible con la naturaleza del mandato, las leyes creadas por la vía democrática no pueden ser reconocidas como mandatos. Si las comparamos a mandatos, tendremos que eliminar por abstracción el hecho de que tales "mandatos" son expedidos por aquellos a quienes se dirigen. Únicamente es posible caracterizar las leyes democráticas como mandatos si se ignora la relación existente entre los individuos que expiden el mandato y aquellos a quienes se dirige, y sólo se acepta una relación entre los últimos y el mandato considerado como autoridad impersonal y anónima. Es la autoridad de la ley la que manda sobre las personas individuales a quienes la misma se refiere. Esta idea de que la fuerza obligatoria emana, no de un ser humano mandante, sino de un "mandato" impersonal y anónimo, está expresada en las famosas palabras *non sub homine, sed sub lege*. Si una relación de superioridad e inferioridad se incluye en el concepto de mandato, entonces las reglas de la ley sólo son mandatos si consideramos al ligado a ellas como destinatario de las mismas. El "mandato" impersonal y anónimo es precisamente la norma.

La afirmación de que un individuo "debe" comportarse de cierta manera no implica ni que otro "quiera" o "mande" tal cosa, ni que el que debe comportarse en cierta forma realmente lo haga. La norma es la expresión de la idea de que algo debe ocurrir, especialmente la de que un individuo debe conducirse de cierto modo.

Con la norma nada se dice acerca de la conducta real del destinatario. La afirmación de que un individuo "debe" conducirse de cierta manera significa que este comportamiento está prescrito por una norma, ya se trate de una norma moral, de una norma jurídica o de cualquiera otra. El

"deber ser" simplemente expresa el sentido específico en el cual la conducta humana se encuentra determinada por una norma. Lo único que podemos hacer para describir tal sentido es afirmar que es diferente de aquél en el cual decimos que un individuo realmente se comporta en cierta forma, o que alguna cosa sucede o existe realmente. La afirmación relativa a que algo debe ocurrir es una afirmación sobre la existencia y el contenido de una norma, no sobre la realidad natural, es decir, sobre acontecimientos reales en la naturaleza.

Una norma que expresa la idea de que algo debe ocurrir —aun cuando es posible que no ocurra realmente—, es "válida". Y si el suceso al cual se hace referencia es el comportamiento de cierto individuo, y la norma dice que debe conducirse de cierta manera, entonces la norma "obliga" a éste. Únicamente con ayuda del concepto de norma y de la noción correlativa del "deber ser" podemos captar la significación específica de los preceptos del derecho. Sólo de esta manera podemos entender su importancia para aquellos cuya conducta "establecen" o para aquellos a quienes "prescriben" una cierta forma de comportamiento. Cualquier ensayo para presentar la significación de las normas jurídicas como reglas que describen la conducta real de los hombres y ofrecer así la significación de tales normas sin recurrir al concepto del "deber ser", está condenado al fracaso. Ni una afirmación sobre la conducta real de quienes crean la norma, ni el juicio sobre la conducta real de los sujetos a ella, pueden entregarnos el sentido específico de la norma.

En resumen: decir que una norma "vale" para ciertos individuos, no es lo mismo que afirmar que determinado o determinados individuos "quieren" que otros se conduzcan en tal o cual forma; pues la norma es válida incluso cuando tal voluntad no existe. Declarar que una norma es válida para ciertas personas no equivale a decir que los individuos realmente se comportan en determinada forma; pues la norma es válida para tales individuos aun cuando se conduzcan de otro modo. La distinción entre el "deber ser" y el "ser" es fundamental para la descripción del derecho.

b) Normas generales y normas individuales

Si el derecho es caracterizado como un conjunto de "reglas", es necesario subrayar que las jurídicas difieren esencialmente de las demás y, en particular, de aquellas que son presentadas como leyes de la naturaleza (en el sentido de la física). Mientras que las leyes de la naturaleza son afirma-

ciones sobre el curso real de los fenómenos, las reglas jurídicas son prescripciones relativas a la conducta de los hombres. Las leyes de la naturaleza son reglas que describen en qué forma ocurren realmente los fenómenos naturales y por qué tales fenómenos se producen, es decir, cuáles son sus causas. Las reglas del derecho refiérense exclusivamente al comportamiento humano; establecen en qué forma debe el hombre conducirse, y nada indican acerca de la conducta real de los hombres o de las causas de dicha conducta. A fin de evitar malos entendimientos (en lo que se refiere a la naturaleza del derecho), es mejor no usar en este contexto el término "regla", sino caracterizar al derecho como conjunto de normas.

Otra razón por la cual la designación del derecho como "regla" se presta a confusiones, está en que la palabra "regla" tiene la connotación de algo "general". Una "regla" no se refiere a un solo acontecimiento que no vuelve a repetirse, sino a toda una clase de sucesos semejantes. El significado de la regla es que un fenómeno de cierta clase se realice —o deba realizarse— siempre o casi en todos los casos en que se cumplan determinadas condiciones de tal o cual especie. De hecho, el orden jurídico es a menudo explicado como un conjunto de "reglas generales". Austin¹⁸ establece una distinción explícita entre "leyes" y "mandatos particulares": cuando un mandato, dice el citado autor, "obliga *generalmente* a actos u omisiones de cierta *clase*, el mandato es una ley o regla. Pero cuando obliga a un acto o a una omisión *específicos*... el mandato es ocasional o particular". Habiendo identificado los términos "derecho" y "regla", únicamente podemos considerar como leyes las normas generales. Mas no hay duda de que el derecho no consiste solamente en normas generales. Incluye también las individuales, es decir, las que determinan la conducta de un individuo en una situación no recurrente; y que, por tanto, son válidas sólo para un caso particular y pueden ser obedecidas y aplicadas solamente una vez. Tales normas son "derecho" porque forman parte del orden jurídico total, exactamente en el mismo sentido que aquellas normas generales que han servido de base para la creación de las primeras. Ejemplos de tales normas particulares son las decisiones de los tribunales, en la medida en que su fuerza obligatoria se encuentra limitada al caso particular de que se trata. Supóngase que un juez ordena al deudor A devolver 1,000 pesos a su acreedor B. Al amenazar en forma expresa o tácita al sujeto A con una sanción civil para el caso de incumplimiento, el juez "ordena" a tal sujeto pagar 1,000 pesos a B. La decisión del juez es norma jurídica en

el mismo sentido y por la misma razón que el principio abstracto según el cual si una persona no devuelve la cantidad prestada debe imponérsele una sanción civil, a petición del acreedor. La "fuerza obligatoria" o "validez" de la ley se encuentra intrínsecamente referida no a su posible carácter general, sino únicamente a su carácter de norma. Tomando en cuenta que, por su misma naturaleza, el derecho es una norma, no hay razón para considerar exclusivamente como jurídicas las normas generales. Si las individuales presentan en otros aspectos las características esenciales del derecho, habrá que considerarlas también como partes de éste.

c) Normas condicionales e incondicionales

Las normas generales tienen siempre la forma de proposiciones hipotéticas. La sanción estipulada por la norma se hace depender de la realización de ciertas condiciones. También una norma jurídica individual puede asumir forma hipotética. La resolución judicial antes mencionada, puede servir como ejemplo. La sanción civil se estipula bajo la condición de que el demandado no cumpla la conducta prescrita por el tribunal. Hay, sin embargo, normas jurídicas especiales que no tienen carácter hipotético. Por ejemplo, cuando una corte penal establece que determinado individuo es culpable de tal o cual delito y le impone determinada pena, por ejemplo, dos años de cárcel, el tribunal crea, sobre la base de la norma hipotética general, la norma individual de que el acusado debe ser privado de su libertad durante dos años. La norma especial es en este caso incondicional.

d) Norma y acto

La ejecución de la decisión del tribunal —el proceso que implica que el condenado sea realmente metido en la cárcel y retenido allí durante dos años— no es por sí misma norma jurídica. Si designamos tal proceso como un "acto jurídico", y en esta forma indicamos que pertenece también al derecho, entonces la definición de éste como un conjunto de normas podría parecer demasiado estrecha. No únicamente la ejecución de una norma de derecho, la realización de la sanción que aquélla estipula, sino también los actos por los cuales las normas jurídicas son creadas, son de carácter jurídico. Una peculiaridad del derecho que posee extraordinaria importancia teórica y que será más tarde discutida por nosotros,

¹⁸ *JurisPrudence*, 92 f.

es la de que regula su propia creación. El acto a través del cual una norma jurídica, general o especial, es creada, representa por consiguiente un acto determinado por el orden jurídico, lo mismo que constituye la ejecución de otra norma. Un acto es jurídico precisamente en cuanto se encuentra determinado por una norma de derecho. La calidad jurídica de un acto se identifica con su relación frente a una norma de derecho. Un acto es "jurídico" sólo en cuanto y porque se encuentra determinado por una norma de derecho. Por ello es incorrecto decir que el derecho consiste en normas y en actos. Sería más correcto afirmar que el derecho está integrado por normas jurídicas y actos jurídicos determinados por tales normas. Si adoptamos un punto de vista estático, es decir, si consideramos el orden jurídico únicamente en su forma completa o en un estado de inmovilidad, advertiremos únicamente la existencia de las normas por las cuales los actos jurídicos se encuentran determinados. Si adoptamos, por otra parte, el punto de vista dinámico, y consideramos el proceso a través del cual el orden jurídico es creado y ejecutado, entonces sólo veremos los actos de creación y ejecución del derecho. Más tarde volveremos sobre esta importante distinción entre estática y dinámica jurídicas.

e) *La eficacia como conformidad de la conducta con la norma*

En lo que antecede hemos tratado de esclarecer la diferencia entre validez y eficacia del derecho. Validez del derecho significa que las normas jurídicas son obligatorias, que los hombres deben conducirse como éstas lo prescriben, y que deben obedecer y aplicar las mismas normas. La eficacia del derecho quiere decir que los hombres se comportan en la forma en que, de acuerdo con las normas jurídicas, deben comportarse; o sea, que las normas son realmente aplicadas y obedecidas. La validez es una cualidad del derecho; la llamada eficacia, una cualidad de la conducta real de los hombres y no, como parece sugerirlo el uso lingüístico, del derecho mismo. La afirmación de que el derecho es eficaz significa solamente que la conducta real de los individuos se ajusta a las normas jurídicas. Así, pues, validez y eficacia se refieren a fenómenos completamente distintos. La afirmación común de que tanto la validez como la eficacia son atributos del derecho, se presta a confusión, incluso cuando por eficacia del derecho se quiere expresar que la idea de éste ofrece un motivo para la conducta jurídica. El derecho como norma válida encuentra su expresión en el aserto de que los hombres deben conducirse de cierta manera, es de-

cir, en una afirmación que nada dice sobre acontecimientos reales. Entendida de este modo, la eficacia del derecho consiste en que los hombres sean llevados a observar la conducta prescrita, gracias a la representación de la norma. El aserto relativo a la eficacia del derecho, entendida en la forma que acabamos de indicar, es un aserto sobre la conducta real de los individuos. Aplicar la palabra "norma" tanto a la norma válida como a la idea de la norma, que es un nuevo hecho psicológico, es cometer una equivocación que puede producir graves falacias. Pero como ya lo he indicado, no estamos en situación de decir nada con exactitud acerca del poder de motivación que deba atribuirse a la idea que los hombres se forman del derecho. Objetivamente sólo podemos afirmar que la conducta de los individuos se ajusta o no se ajusta a lo prescrito por las normas jurídicas. La única connotación que en este trabajo atribuimos al término "eficacia" es, por ende, la de que la conducta real de los hombres concuerda con esas normas.

f) *La conducta "opuesta" a la norma*

El juicio de que una conducta real se "conforma" con una norma o el de que la conducta de alguien es como debe ser de acuerdo con la norma, puede caracterizarse como un juicio de valor. Trátase del que afirma una relación entre un objeto, especialmente la conducta humana, y una norma que el individuo que juzga supone como válida. Tal juicio de valor debe ser cuidadosamente distinguido de la afirmación de que hay una relación entre el objeto y un interés del individuo que juzga, o de otros individuos. Al juzgar que algo es "bueno" podemos significar que nosotros (es decir, el sujeto que juzga u otros individuos) deseamos ese algo o lo encontramos agradable. Entonces nuestro juicio afirma un estado real de las cosas: lo que afirmamos es nuestra propia actitud emocional o la de otros frente a aquello que llamamos "bueno". Lo mismo vale para el juicio que afirma que algo es "malo", si al emitirlo expresamos nuestra actitud hacia el objeto, esto es, que no lo deseamos o lo encontramos desagradable. Si designamos tales juicios como juicios de valor, entonces se tratará de afirmaciones sobre hechos reales, que no diferirán —en principio— de otros juicios acerca de la realidad.

El juicio de que algo —particularmente la conducta humana— es “bueno” o “malo”, puede también significar algo distinto de lo que significa la afirmación de que yo, que hago el juicio, u otros individuos, deseamos o no la conducta, es decir, la encontramos agradable o desagradable. Seméjante juicio puede también expresar la idea de que la conducta es o no conforme a una norma cuya validez presupongo. La norma es usada en este caso como un criterio estimativo.¹⁹ Podría también decirse que en tal caso los hechos reales son “interpretados” a la luz de una norma. La norma cuya validez se supone sirve entonces como un esquema de interpretación. El que una acción o una omisión se ajuste a una norma válida, o sea “buena” (en el sentido más general de la palabra), significa que el individuo a quien la norma se refiere ha observado realmente la conducta que de acuerdo con tal norma debía observar. Si la norma estipula la conducta A, y la conducta real del individuo es también A, entonces dicho comportamiento “concuerda” con la norma. Representa la realización de la conducta que la norma estipula. El que el comportamiento de un individuo sea “malo” (en el sentido más general de la palabra), significa que tal conducta se opone a una norma válida; que el individuo no ha observado el comportamiento que de acuerdo con la norma debía haber observado. Su conducta no es entonces una realización de lo que la norma estipula. La norma ordena la conducta A; pero el comportamiento real del individuo es no-A. En tal caso decimos: la conducta de éste “contradice” a la norma. Esta “contradicción” no es sin embargo un contradicción lógica. Aun cuando haya una contradicción lógica entre A y no-A, no la hay entre la afirmación que expresa el significado de la norma: “el individuo debe conducirse en la forma A”, y la afirmación que describe la conducta real del mismo individuo: “el individuo se comporta en la forma no-A”. Tales afirmaciones son perfectamente compatibles entre sí. Una contradicción lógica únicamente puede tener lugar entre dos afirmaciones que postulan el mismo “deber ser” o sea, entre dos normas; por ejemplo: “X debe decir la verdad” y: “X no debe decir la verdad”; o entre dos juicios que afirman un “ser”; por ejemplo: “X dice la verdad” y “X no dice la verdad”. Las relaciones de “conformidad” o “discrepancia” son relaciones entre una norma que prescribe cierta conducta y es considerada como válida, por una parte, y la conducta real de los hombres, por otra.

¹⁹ Cf. *infra*, p. 56.

g) Eficacia como condición de validez

La afirmación de que una norma es válida y la de que es eficaz son, en realidad, diferentes. Pero si bien validez y eficacia son dos conceptos enteramente distintos, entre ellos hay, sin embargo, una relación muy importante. Una norma es considerada como válida sólo bajo la condición de que pertenezca a un sistema normativo, a un orden que, considerado en su totalidad, es eficaz. Así pues, la eficacia es condición de la validez, pero no la razón de la misma. Una norma no es válida *porque* es eficaz; es válida si el orden al cual pertenece tiene, en general, eficacia. Esta relación entre validez y eficacia sólo es cognoscible, sin embargo, desde el punto de vista de una teoría dinámica del derecho, que se ocupe en el problema de la razón de validez y en el del concepto de orden jurídico.²⁰ Desde el punto de vista de una teoría estática sólo viene en cuestión el problema de la validez.

h) El ámbito de validez de las normas

Como las normas regulan la conducta humana, y ésta tiene lugar en el tiempo y en el espacio, las normas son válidas para cierto tiempo y para un espacio determinado. La validez de una norma puede principiar en un momento y terminar en otro. Las del derecho checoslovaco empezaron a ser válidas un cierto día de 1918; las del derecho austriaco dejaron de serlo en 1938, el día en que la República Austriaca fue incorporada al Estado Alemán. La validez de una norma tiene también relación con el espacio. Para ser válida, tiene que serlo no sólo en cierto tiempo, sino también para cierto territorio. Las del derecho francés son válidas únicamente en Francia, las del mexicano únicamente en México. Podemos, por tanto, hablar de la esfera temporal y de la esfera territorial de validez de una norma. Para determinar cómo deben los hombres conducirse, es necesario determinar cuando y dónde habrán de comportarse en la forma prescrita. Cómo habrán de conducirse y qué actos deberán realizar u omitir, es lo que constituye la esfera material de validez de la norma. Las que regulan la vida religiosa de los hombres se refieren a una esfera material de validez distinta de la de aquellas que regulan su vida económica. Con

²⁰ Cf. *infra*, p. 139, c).

referencia a una cierta norma es posible, sin embargo, plantear no solamente el problema sobre lo que se debe hacer u omitir, sino también la cuestión concerniente a quién debe observar u omitir determinada conducta. El último interrogante se refiere a la esfera personal de validez de la norma. Así como hay normas válidas únicamente para un determinado territorio, para cierto período de tiempo, y con respecto a ciertas materias, también hay normas válidas sólo para determinados individuos, por ejemplo, para católicos o para suizos. La conducta humana que forma el contenido de las normas y que ocurre en el tiempo y en el espacio está constituida por un elemento personal y otro material: el individuo que en cierto lugar y en cierta época hace o deja de hacer algo, y la cosa o acto que hace o se abstiene de hacer. Así pues, las normas tienen que regular la conducta humana en todos los respectos indicados.

Entre las cuatro esferas de validez de la norma, la personal y la material tienen prioridad sobre la territorial y la temporal. Las últimas son únicamente el territorio dentro del cual y el tiempo durante el cual el individuo debe observar determinada conducta. Una norma puede determinar el tiempo y el espacio sólo en relación con la conducta humana. Declarar que una norma es válida para un determinado territorio equivale a sostener que se refiere al comportamiento humano que ocurre dentro de ese territorio. Decir que una norma es válida para cierto tiempo equivale a afirmar que se refiere a la conducta humana que se realice durante ese tiempo. Cualquier territorio en el cual y cualquier tiempo durante el cual se realice la conducta humana pueden constituir las esferas territorial y temporal de validez normativa.

Ocasionalmente se afirma que las normas no pueden tener validez para el pasado, sino únicamente para el futuro. Ello no es así, y el aserto de que hablamos parece deberse a la falta de distinción entre la validez y la eficacia de la representación de la norma. La representación de una norma, como hecho psíquico, puede llegar a ser eficaz sólo en el futuro, en el sentido de que tal representación debe preceder temporalmente a la conducta conforme a la norma, pues la causa tiene que ser temporalmente anterior al efecto. Pero la norma puede referirse también a un comportamiento pasado. Pasado y futuro son relativos a ciertos momentos del tiempo. El momento de tiempo que tienen presente aquellos que afirman que una norma es válida sólo para el futuro, es evidentemente el de su creación. Lo que quieren decir es que las normas no pueden referirse a acontecimientos ocurridos antes de ese momento. Pero este aserto no se justifica

si consideramos que la validez de una norma es algo diverso de la eficacia de su representación. Nada nos impide aplicar una norma, como esquema interpretativo o criterio de estimación, a hechos que ocurrieron antes del momento en que empezó a tener existencia. Lo que alguien quiso en el pasado podemos juzgarlo estimativamente de acuerdo con una norma que adquirió su validez con posterioridad a ese hecho. En un pasado remoto el sacrificio de seres humanos a la divinidad era un deber religioso, y la esclavitud se consideraba como institución jurídica. En la actualidad declaramos que esos sacrificios humanos eran crímenes y que la esclavitud, como institución jurídica, era inmoral. Aplicamos normas morales válidas en nuestro tiempo a esos hechos, aun cuando las que prohíben los sacrificios humanos y la esclavitud hayan empezado a existir mucho tiempo después de los hechos que, de acuerdo con tales normas, juzgamos ahora como crímenes e inmoralidades. La legitimación subsecuente es posible y frecuente, especialmente en el campo del derecho. Un ejemplo especial es la ley alemana por la cual ciertos asesinatos, cometidos por órdenes del Jefe del Estado el 30 de junio de 1934, fueron retroactivamente desprovistos de su carácter delictuoso. También habría sido posible dar retroactivamente a esos asesinatos el carácter de sanciones. Una norma jurídica, una ley, por ejemplo, puede enlazar una sanción a hechos realizados antes de la creación de la misma. Esta norma es válida tanto para el sujeto que debe abstenerse del delito, como para el órgano obligado a ejecutar la sanción. Tal norma es, en relación con el particular obligado, válida para el pasado.

i) *Leyes retroactivas e "ignorantia juris"*

Se puede discutir el valor moral y político de las leyes retroactivas, pero no dudar acerca de su posibilidad. La Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, dice en su artículo 1, sección 9, cláusula 3: "No podrán expedirse leyes *ex post facto*". El término "*ley ex post facto*" es interpretado como ley penal con fuerza retroactiva. Las leyes retroactivas se consideran objetables e indeseables, porque hieren nuestro sentimiento de justicia al imponer una sanción, especialmente un castigo, a consecuencia de una acción u omisión relativamente a las cuales el individuo sancionado ignoraba que tendrían como consecuencia dicha sanción. Sin embargo, por otra parte se reconoce el principio —fundamentalmente en todos los órdenes jurídicos positivos— según el cual *ignorantia juris neminem*

excusar, la ignorancia del derecho a nadie sirve de excusa. La circunstancia de que un individuo ignore que el derecho atribuye una sanción a sus actos u omisiones, no es razón para que la sanción no le sea imputada. Algunas veces ese principio es interpretado restrictivamente: la ignorancia del derecho no sirve de excusa si el individuo a quien era posible conocer la ley no la conocía. El principio no parece entonces incompatible con la repudiación de las leyes retroactivas. Pues en el caso de una ley retroactiva es realmente imposible conocer ésta en el momento en que se realiza el acto al cual la ley enlaza la sanción. Sin embargo, la distinción entre el caso en el cual el individuo puede conocer la ley en el momento en que comete el hecho anti-jurídico, y aquel en que la persona no puede conocer la ley, es más que problemática. De hecho, generalmente se presupone que la vigente puede ser conocida por los individuos cuya conducta regula. Esta es, en realidad, una *praesumptio iuris et de jure*, es decir, una "presunción que no admite prueba en contrario", o "presunción irrebatible", una hipótesis legal cuya incorrección no está sujeta a prueba, a saber: la de que las normas de un orden jurídico positivo pueden ser conocidas por los individuos sometidos a ese orden. Es obvio que ello no es verdad; la presunción de que hablamos es una ficción jurídica típica. De aquí que, con respecto a la posibilidad o imposibilidad de conocimiento de la ley, no exista ninguna diferencia esencial entre una ley retroactiva y muchos casos en los cuales otra no retroactiva no es ni puede ser conocida por el individuo a quien tiene que aplicarse.

D) LA NORMA JURÍDICA

a) Norma jurídica y regla de derecho en sentido descriptivo

Si la "coacción" en el sentido aquí definido es un elemento esencial al derecho, entonces las normas que forman un orden jurídico tienen que ser normas que establezcan actos coercitivos, es decir: sanciones. En particular, las normas generales tienen que ser normas en las cuales una cierta sanción se hace depender de determinadas condiciones, expresándose tal dependencia mediante el concepto del "deber ser". Esto no significa que los órganos legisladores tengan necesariamente que dar a las normas la forma de juicios hipotéticos que establecen "deberes". Los diferentes elementos de una norma pueden quedar contenidos en muy diversos productos del proceso legislativo y expresarse lingüísticamente de maneras muy diversas.

Cuando el legislador prohíbe el robo, por ejemplo, puede definir primeramente el concepto de robo valiéndose de varias frases que forman un artículo de un código, y señalar después la sanción en otra frase, que puede formar parte de otro artículo del mismo texto, o incluso de un texto legal distinto. A menudo, la última frase no tiene la forma lingüística de un imperativo o de un juicio que exprese un "deber ser", sino la de predicción de un acontecimiento futuro. Frecuentemente, el legislador hace uso del futuro al decir que el ladrón "será" castigado en tal o cual forma. Entonces presupone que el problema sobre quién es ladrón ha quedado resuelto en alguna otra parte, en el mismo o en otro texto legal. La frase "será castigado" no implica la previsión de un hecho venidero —el legislador no es un profeta— sino que constituye un "imperativo" o "mandato", tomados estos términos en sentido figurado. Lo que la autoridad creadora de la norma quiere decir es que la sanción "debe ser" ejecutada contra el ladrón, si se realiza el supuesto condicionante de la misma.

Es tarea de la ciencia jurídica presentar el derecho de una comunidad, esto es, el material producido por la autoridad legal, a través del proceso legislativo, en la forma de juicios que establezcan que "si tales o cuales condiciones se cumplen, entonces tal o cual sanción habrá de aplicarse". Estos juicios, por medio de los cuales la ciencia jurídica expresa el derecho, no deben ser confundidos con las normas creadas por las autoridades encargadas de legislar. Es preferible no dar a estos juicios el nombre de normas, sino el de reglas jurídicas. Las normas jurídicas formuladas por los órganos legislativos son prescriptivas; las reglas del derecho que la ciencia jurídica establece son puramente descriptivas. Importa tener en cuenta que el término "regla jurídica" o "regla de derecho", es empleado por nosotros en sentido descriptivo.

b) Regla de derecho y ley de la naturaleza

La regla de derecho, usado el término en sentido descriptivo, es un juicio hipotético que enlaza ciertas consecuencias a determinadas condiciones. Esta es la forma lógica que tienen también las leyes naturales. Lo mismo que la ciencia jurídica, la de la naturaleza describe su objeto en proposiciones que ostentan el carácter de juicios hipotéticos. Y como en la proposición jurídica, la ley natural enlaza igualmente, como condición y consecuencia, dos hechos físicos. La condición es, en este caso, la "causa"; la consecuencia, el "efecto". La forma fundamental de la ley natural es la

causalidad. La diferencia entre la regla de derecho y la ley de la naturaleza parece consistir en que la primera se refiere a seres humanos y a su conducta, mientras que la segunda se refiere a las cosas y a sus reacciones. La conducta humana puede, sin embargo, ser materia de las leyes naturales, en la medida en que tal conducta pertenece también a la naturaleza. La regla de derecho y la ley natural difieren no tanto en los elementos que enlazan sino en la forma de tales enlaces. La ley natural establece que si A es, B es (o será). La regla de derecho dice: si A es, B debe ser. La regla de derecho es una norma (en el sentido descriptivo del vocablo). El significado de la conexión establecida por la ley natural entre los dos elementos queda expresado en la palabra "es", mientras que el significado de la establecida por la regla de Derecho queda expresado mediante las palabras "debe ser". El principio de acuerdo con el cual la ciencia natural describe su objeto, es la causalidad; el principio de acuerdo con el cual la ciencia del derecho describe el suyo, es la normatividad.

Usualmente, la diferencia entre ley natural y norma es caracterizada por la afirmación de que la primera no puede tener excepciones, en tanto que la segunda sí puede tenerlas. Sin embargo, tal afirmación no es correcta. La regla normativa: "si alguien roba deberá ser castigado", conserva su validez aun en el caso de que un ladón quede impune. Tal hecho no implica una excepción al deber ser expresado por la norma; es únicamente una excepción al juicio enunciativo que expresa la regla de que, si alguien roba, realmente será castigado. La validez de una norma subsiste aun cuando, en un caso concreto, los hechos no correspondan a ella. Un hecho tiene el carácter de "excepción" a una regla, si el juicio que establece el hecho se encuentra en contradicción lógica con tal regla. Como la norma no es un juicio de realidad, ningún juicio sobre un hecho real puede contradecirla. De aquí que no pueda haber excepciones a una norma. Por su misma naturaleza, la norma es inviolable. Declarar que una norma es "violada" por cierta conducta es una expresión figurada; y la figura empleada no es correcta. Pues el juicio nada dice acerca de la norma; simplemente describe la conducta real como contraria a la que la norma prescribe.

La ley de la naturaleza no es sin embargo inviolable.²¹ Es posible que una ley natural tenga verdaderas excepciones. El enlace entre causa y efecto establecido en una ley natural descriptiva de la realidad física, tiene sólo el carácter de probabilidad, no el de necesidad absoluta pretendido por la vieja

21 William A. Robison, *Civilization and the Growth of Law* (1935), 349, dice: "Los hombres de ciencia ya no pretenden, para las leyes naturales, esa validez inexorable, inmutable y objetiva que anteriormente se les atribuía."

filosofía de la naturaleza. Si, como resultado de la investigación empírica, dos fenómenos se consideran en relación de causa y efecto, y tal resultado se formula en una ley natural, no queda absolutamente excluido que un hecho pueda ocurrir en contradicción con esa ley, y constituya, por tanto, una verdadera excepción a la misma. Si tal hecho queda establecido, entonces la formulación de la ley tiene que ser modificada de manera que el hecho nuevo corresponda a la nueva fórmula. Pero la conexión de causa a efecto establecida por ésta tiene solamente, como la antigua formulación, el carácter de probabilidad, no el de necesidad absoluta. Las excepciones a la ley no quedan excluidas.

Si examinamos la forma en la cual la idea de causalidad se ha desarrollado en el espíritu humano, encontraremos que tiene su origen en una norma. La interpretación de la naturaleza poseía originariamente carácter social. El hombre primitivo considera a la naturaleza como parte constitutiva de la sociedad a que pertenece. La realidad física es interpretada por él de acuerdo con los mismos principios que determinan sus relaciones sociales. A sus ojos, el orden social es, al propio tiempo, el de la naturaleza. Así como los hombres obedecen las normas del orden social, las cosas están sometidas a normas emanadas de seres personales sobrehumanos. La ley social fundamental es aquella que establece que el bien debe ser recompensado, y el mal castigado. Trátase del principio de retribución, que domina completamente la conciencia primitiva. La norma jurídica es el prototipo de tal principio. El hombre primitivo interpreta la naturaleza de acuerdo con el mismo principio. Su interpretación tiene un carácter jurídico normativo. La ley de causalidad encuentra su origen en la norma de retribución, y se desarrolla a consecuencia de un paulatino cambio de significado. Incluso durante el siglo XIX, la ley de causalidad era concebida como una norma, a saber, como expresión de la divina voluntad. El último paso en esta emancipación de la ley de causalidad, relativamente a la norma de retribución, consiste en el hecho de que la primera se despoja de su carácter normativo y deja, por tanto, de ser concebida como inviolable.²²

c) La norma jurídica como criterio de valoración²³

La norma jurídica puede tener aplicación, no únicamente en cuanto es ejecutada por un órgano u obedecida por los particulares, sino también en

22 Cf. mi libro *Society and Nature*, p. 233.

23 Cf. mi artículo *False Judgments in the Science of Law* (1942), 7, "J. of Social Philosophy and Jurisprudence", 312-333.

cuanto sirve de base para un juicio estimativo específico que califica la conducta del órgano o del particular como legal (debida) o ilegal (indebida). Estos juicios son juicios de valor específicamente jurídicos. Otros juicios estimativos se refieren al derecho mismo, o a la actividad de los individuos que crean la ley. Tales juicios afirman que la actividad del legislador o el producto de la misma, la ley, son justos o injustos. Es cierto que la actividad del juez es también considerada como justa e injusta, pero sólo en cuanto realiza una función creadora de derecho. En la medida en que simplemente aplica la ley, su conducta es considerada como legal e ilegal, en la misma forma en que puede serlo la de los particulares. Los predicados de valor implicados en los juicios que afirman que cierta conducta es legal o ilegal, serán designados por nosotros como "valores de la legalidad", mientras que aquellos implicados en juicios que afirman que el orden jurídico es justo e injusto serán denominados "valores de justicia". Los juicios que afirman la existencia de valores de legalidad son objetivos, los que afirman la existencia de valores de justicia, subjetivos. El juicio jurídico de valor de que cierta conducta es legal o ilegal, es un aserto sobre una relación positiva o negativa entre la conducta y una norma jurídica cuya existencia se presupone por la persona que juzga. La existencia de una norma jurídica es su validez; y aun cuando la validez de las normas jurídicas no se identifica con ciertos hechos, está condicionada por ellos. Estos hechos son —como lo veremos en una sección posterior—²⁴ la eficacia del orden jurídico total a que la norma pertenece, la presencia de un hecho creador de la norma, y la ausencia de cualquier otro hecho que pueda anularla. Un juicio jurídico de valor que afirma una relación positiva o negativa entre una conducta humana determinada y una norma jurídica, implica la afirmación de la existencia de dicha norma. Este aserto y, por tanto, el mismo juicio jurídico de valor, pueden ser verificados por medio de los hechos que condicionan la existencia de la norma. En este sentido, el juicio jurídico de valor tiene un carácter objetivo. La existencia del valor de legalidad es objetivamente comprobable. El valor de justicia, sin embargo, no es de la misma naturaleza que el de legalidad. Cuando estimamos un orden jurídico o una institución jurídica como justos o injustos pretendemos decir algo más que cuando llamamos a un platillo bueno o malo, en el sentido de afirmar que lo encontramos agradable o no al paladar. La afirmación de que una institución jurídica, la esclavitud o la propiedad privada, por ejemplo, son justas o injustas, no quiere decir que alguien tenga un

²⁴ Cf. *infra*, p. 139, e).

interés en tal institución o lo contrario. Lo significado es que la institución corresponde o no a una norma cuya validez se presupone por la persona que juzga. Pero tal norma no pertenece al derecho positivo. El juicio de justicia pretende, empero, expresar un valor objetivo.

Las normas que son realmente empleadas como criterios de justicia varían, según lo hemos indicado, de individuo a individuo, y a menudo son inconciliables entre sí. Una cosa es justa o injusta únicamente para el individuo frente al cual existe la correspondiente norma de justicia, y tal norma tiene existencia sólo para aquellos que, por una u otra razón, desean lo que la misma prescribe. Es imposible determinar tal norma de una manera única. En última instancia constituye la expresión del interés del individuo que declara que determinada institución social es justa o injusta. Esto es, sin embargo, algo de lo cual no tiene conciencia. Su juicio pretende afirmar que hay una justicia independiente de la voluntad humana. Esta pretensión de objetividad es particularmente evidente cuando la idea de justicia aparece bajo la forma de "derecho natural". De acuerdo con la doctrina del *ius naturalé*, la norma de justicia es immanente a la naturaleza —la naturaleza del hombre o la de las cosas— y el hombre sólo puede captar, pero no crear o modificar dicha norma. La doctrina de que hablamos es una ilusión típica, debida a la objetivación de intereses subjetivos.

Los valores de justicia no consisten, es verdad, en una relación con una norma. Esta, empero, no es, como lo cree la persona que juzga, objetiva, sino que depende de un interés subjetivo del juzgador. No hay pues, por consiguiente, un solo criterio de justicia, sino gran número de criterios distintos e incongruentes entre sí.

El derecho positivo es sin embargo uno solo. O —si queremos tomar en cuenta la existencia de los varios órdenes jurídicos nacionales— sólo hay para cada territorio un derecho positivo. El contenido de los mismos únicamente puede ser determinado mediante un método objetivo. La existencia de los valores de legalidad está condicionada por hechos objetivamente verificables. A las normas de derecho positivo corresponde una determinada realidad social, no así a las de la justicia. En este sentido el valor del derecho es objetivo, mientras que el de la justicia es subjetivo. Desde este punto de vista es indiferente que un gran número de personas tenga a veces un mismo ideal de justicia. Los juicios jurídicos de valor son juicios que pueden ser objetivamente comprobados con ayuda de los hechos. Por ello son admisibles dentro del ámbito de la ciencia del derecho. Los de justicia no pueden ser objetivamente comprobados. Consecuentemente, la ciencia jurídica no tiene lugar para ellos.

Los morales y políticos son de la misma naturaleza que los juicios de justicia. Todos tienden a expresar un valor objetivo. De acuerdo con su significación, el objeto a que se refieren es valioso para todo el mundo. Presuponen una norma objetivamente válida. Pero la existencia y contenido de ésta no pueden ser verificados con ayuda de los hechos. Hallanse determinados únicamente por un deseo subjetivo de la persona que juzga. Los juicios morales y políticos de valor y, en particular, los de justicia, basanse en ideologías que, a diferencia de los jurídicos de valor, no existen paralelamente a una determinada realidad social.

II. LA SANCION

El concepto de regla jurídica en sus dos aspectos —la regla de derecho como norma creada por una autoridad jurídica para regular la conducta humana, y como instrumento empleado por la ciencia jurídica para describir el derecho positivo— es el concepto central de la jurisprudencia. Otros fundamentales son los de sanción, acto anti-jurídico, deber jurídico, derecho subjetivo, sujeto de derecho y orden jurídico.

Las sanciones son establecidas por el orden jurídica para provocar cierta conducta humana que el legislador considera deseable. Las sanciones jurídicas tienen carácter de actos coercitivos en el sentido arriba indicado. Originariamente sólo había una especie de sanción: la penal, esto es, el castigo —en el sentido estricto de la palabra— en relación con la vida, la salud, la libertad o la propiedad. El derecho más antiguo era exclusivamente penal. Más tarde se hizo un distinguo por lo que toca a la sanción: además del castigo apareció una sanción civil específica, la ejecución forzada o privación coactiva de la propiedad con el propósito de establecer una reparación, es decir, una compensación por los daños causados ilegalmente. Entonces se desarrolló el derecho civil al lado del penal. Pero el civil, regulador de la vida económica, garantiza en ese campo la conducta deseada de una manera que no difiere esencialmente de aquella en la cual el criminal lo hace dentro de su propia esfera, a saber: estableciendo para el caso de una conducta contraria una medida coercitiva específica, es decir, la sanción civil. La diferencia entre el derecho civil y el penal es una diferencia en el carácter de sus respectivas sanciones. Si consideramos únicamente la naturaleza externa de las sanciones, no podemos encontrar, relativamente a ellas, características distintivas generales. Por ejemplo: aun cuando la